

La responsabilidad internacional resultante de la comisión de un "crimen internacional" (*)

RAFAEL CASADO RAIGÓN

SUMARIO:

I. INTRODUCCION: 1. Respuesta tradicional a la relación jurídica de responsabilidad internacional; 2. Datos para una revisión de esa respuesta tradicional; 3. Los orígenes de la "distinción" en la Sexta Comisión de la A.G. y en la Comisión de Derecho Internacional.

II. LA DISTINCION ENTRE "CRIMENES" Y "DELITOS" INTERNACIONALES: 4. El Proyecto de artículo 19; 5. la terminología elegida; 6. Responsabilidad "penal" y estructura de la sociedad internacional contemporánea; 7. Otras precisiones sobre el proyecto de artículo 19; 8. Reacciones generales a la distinción.

III. REGIMEN JURIDICO DE LOS "CRIMENES" INTERNACIONALES: 9. Introducción; 10. La cuestión previa de los "Estados lesionados"; 11. La calificación del "crimen"; 12. Formas de responsabilidad internacional; 13. El control de las medidas.

IV. CONCLUSION

I. INTRODUCCIÓN

1. La violación, ya sea por acción u omisión, de cualquier obligación establecida por una norma de Derecho internacional (tenga un origen consuetudinario, convencional u otro) hace surgir una relación jurídica nueva, la de la responsabilidad internacional, relación que tradicionalmente, con independencia del contenido de la obligación y de la gravedad de la violación, se ha considerado como una relación bilateral, de Estado a Estado, que se concreta en el deber del sujeto a quien se le imputa esa violación de efectuar una reparación y en el derecho de la víctima a reclamar y obtener, según proceda, una restitución, una indemnización o/y una satisfacción.

En esta dirección, y en el marco de lo estrictamente bilateral, Dionisio ANZILOTTI, a principios del siglo XX, definía la violación del derecho internacional como "causa de relaciones jurídicas que tengan por resultado la restauración del derecho menoscabado" (1), con lo que, -como se ha interpretado (2)- la obtención de la reparación resumía la acción del Esta-

(*) Redactado a principios de 1989, el presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que es intención del autor continuar en un futuro próximo a la luz de los más recientes trabajos, en particular, de la Comisión de Derecho Internacional, así como de datos de la práctica internacional (piénsese, por ejemplo, en la "crisis del Golfo") de indudable transcendencia para este tema.

(1) D. ANZILOTTI: *Teoria della responsabilità dello Stato del diritto internazionale pubblico*, 1902, reimpreso en *Scritti di diritto internazionale pubblico*, Padua, CEDAM, 1956, Tomo 1º, p. 62 (recogida de Roberto AGO, *infra* nota 2).

(2) R. AGO, *Quinto informe sobre la responsabilidad de los Estados*, Documento A/CN.4/291 y Add. 1 y 2, A.C.D.I. 1976, vol. II, 1º p., p. 44, nota 209.

(7) C.P.J.I. *Affaire relative à l'usine de Chorzwów*/demande en indemnité, (fond) Série A, n° 17 (arret n° 13, 13 septembre 1928), p. 29.

(8) Decíamos "a raíz principalmente de la Carta" de N.U. porque en el Pacto de la Sociedad de las Naciones se prevía (arts. 16 y 17) un régimen especial para los supuestos de recurso a la guerra no amparados por el propio Pacto (véase art. 12, par. 1º), régimen que conllevaba la adopción de una serie de medidas o "sanciones" aplicables al agresor por parte de todos los miembros de la organización.

(9) Véase un análisis excelente de esta práctica en R. AGO, *Quinto informe...* cit. pp. 36-43, y en el Informe de la C.D.O. a la A.G. sobre la labor realizada en su vigésimo octavo período de sesiones: Documento A/31/10, A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., pp. 102-107.

(10) Artículos 39 y 1 de la Carta de N.U.

(11) En estos términos, CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, *Soberanía del Estado y Derecho internacional*, Tecnos, Madrid, 1976, pp. 258-9.

(12) De la ingente bibliografía sobre el *ius cogens*, podrían citarse, como obras interesantes pero sin ánimo excluyente, las siguientes: Conference on International Law, Lagonissi (Grecia), 3-8 de Abril de 1966: *The Concept of Jus Cogens in International Law*, Carnegie Endowment for International Peace, Ginebra 1967; GOMEZ ROBLEDO, A.: "Le *ius cogens* international: sa genèse, sa nature, ses fonctions", R.C.A.D.I., 1981-III, pp. 9-218; MAREK, K.: "Contribution à l'étude du *ius cogens* en Droit international", *Recueil d'Etudes de D.I. en hommage à Paul Guggenheim*, Faculté de Droit de Genève et I.H.U.E.I., Ginebra 1968, pp. 426-59; MIAJA DE LA MUELA, A.: "*Ius cogens* y *ius dispositivum* en Derecho internacional público", *Homenaje al Profesor Legaz y Lacambra*, Santiago 1960, Tomo II, pp. 1121-53; SCHWARZENBERGER, G.: "International *Jus Cogens*?", *Texas Law Review*, 1964-

do perjudicado. La propia Corte Permanente de Justicia Internacional señalaba en 1928 que "es un principio de Derecho Internacional, y también una concepción general del derecho, que cualquier violación de un compromiso entraña la obligación de reparar" (13).

Pero esta respuesta tradicional, característica de una sociedad internacional sumamente descentralizada, puramente relacional, de yuxtaposición de soberanías y en la que el consentimiento del Estado adquiere una relevancia exclusivista, ¿no puede ser revisada a la luz de los cambios ciertamente sustanciales acaecidos en la sociedad internacional contemporánea?

2. A raíz principalmente de la Carta de las Naciones Unidas, la relación exclusivamente bilateral que surgía de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito no queda ya tan circunscrita cuando se producen determinadas violaciones al Derecho internacional. El hecho de que un tratado internacional con vocación universal tome un partido tan decidido en la defensa de unos valores que considera esenciales, hace que cualquier grieta al respecto interese no sólo a los Estados o entidades directamente en conflicto. Pero, además de proclamar unos propósitos y unos principios, o, lo que es lo mismo, categorías de obligaciones jurídicas en cuyo respeto se está especialmente interesado, la carta de la N.U. (14) y su posterior desarrollo en la práctica (15) introduce medidas especiales de "represión", o de acción colectiva coercitiva, para las violaciones a esas obligaciones que impliquen una "amenaza a la paz", u "quebrantamiento de la paz" o un "acto de agresión" (16). Por tanto el régimen de responsabilidad internacional aplicable a ciertas hipótesis de hechos internacionalmente ilícitos es diferente al de otras: toda violación del Derecho internacional ya no sólo puede entrañar la obligación de reparar por parte del imputable respecto de la víctima directa.

Además, a raíz de la Carta de N.U.,

la práctica estatal subsiguiente va a consolidar, en Derecho internacional, la existencia de normas jurídicas que recogen los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, los de toda la humanidad, de normas jurídicas que suponen exigencias indispensables para la existencia misma de una sociedad internacional y que, por ello son imperiosas, absolutas, superiores a la voluntad de los Estados (17). Gracias a su arraigo cada vez más profundo en la conciencia jurídica de la humanidad, por guardar relación con valores jurídicos esenciales, estas normas de *ius cogens* ha tenido su entrada en la obra de codificación y desarrollo progresivo del D.I. emprendido por las N.U. a través de su primera formulación positiva en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de Mayo de 1969: Según su artículo 53, la norma imperativa de Derecho internacional general es aquella norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo carácter (18).

De esta forma el *ius cogens* significa una excepción al voluntarismo y relativismo del Derecho internacional, haciendo inoperable la regla *ius posterior derogat iuri priori* si la nueva norma no tiene el mismo carácter imperativo. Por lo tanto, su derogación no es posible y todo "acuerdo" (en sentido amplio) que esté en oposición a la norma de *ius cogens* es nulo (19). Si esto es así, mal puede concebirse - como ha señalado Roberto AGO - que la evolución jurídica de los Estados en cuanto a la idea de la inadmisibilidad de la derogación de ciertas reglas no haya ido acompañada a una evolución paralela en la esfera de la responsabilidad de los Estados: Parecería contradictorio seguir atribuyendo las mismas consecuencias a la violación de obligaciones derivadas de normas definidas como "imperativas" y a la violación de obligaciones emanadas de

normas que pueden ser derogadas mediante acuerdos particulares. Por las mismas razones parecería contradictorio que en caso de violación de una norma de tanta importancia para la comunidad internacional en su conjunto que se la califica de "imperativa", se siga considerando que el vínculo de responsabilidad se establece únicamente entre el Estado autor de la violación y el Estado directamente lesionado por ésta (10).

La propia Corte Internacional de Justicia ha sido sensible -y es sensible- a la evolución que ponemos de manifiesto. En efecto, en no pocas de sus resoluciones, la corte no ha hecho la vista gorda ante normas -y ante situaciones- que, por su importancia -o por lo que implican-, tiene una lectura diferente a la de los demás. Poco tiempo le bastó para invocar "consideraciones elementales de humanidad, más absolutas aún en tiempo de paz que en tiempo de guerra" (11) o para hacer referencia a principios convencionales pero que "obligan a los Estados al margen de todo vínculo convencional" (12). En el asunto de los rehén norteamericanos, por ejemplo, habló del "carácter imperativo de las obligaciones jurídicas que incumben al gobierno de Irán" (13) o en una de sus últimas y más importantes sentencias -la de 27 de Junio de 1976 en el asunto de la actividades militares y paramilitares- el entonces presidente NAGENDRA SINGH, se felicitaba de que la Corte identificara el principio del no uso de la fuerza con el *ius cogens*, principio estrechamente ligado a los "esfuerzos desplegados por la humanidad para promover la paz en el mundo atormentado por las luchas" (14).

Sin embargo, la afirmación más tajante de la Corte Internacional de Justicia en relación a este problema y que, sin duda, constituye una referencia obligada en la historia de su jurisprudencia, es la contenida en la sentencia de 5 de Febrero de 1970 en el asunto de la *Barcelona Traction* al

señalar que:

"Una distinción esencial debe establecerse entre las obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto y las que nacen con respecto a otro Estado en el marco de la protección diplomática. Por su misma naturaleza, las primeras conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en juego, puede considerarse que todos los Estados tienen un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos; las obligaciones de las que se trata son obligatorias *erga omnes*". (15).

En este dictum, es evidente que la Corte está haciendo una referencia expresa al *ius cogens* internacional, con frases que recuerdan al art. 53 de la Convención de Viena de 1969; esa referencia, empero, no está hecha desde el punto de vista de las normas: es evidente que las normas de *ius cogens* dimanarían obligaciones *erga omnes*, es decir, obligaciones que son oponibles a todos (16). Pero, por otra parte, en lo que más debemos fijar nuestra atención es en introducción de un concepto de suma importancia en el terreno de la responsabilidad internacional: la *actio popularis*. Existe acción -al menos en un sentido amplio- por parte de todos los Estados en la observancia de dichas obligaciones porque todos poseen un interés de carácter jurídico para que los derechos subjetivos correlativos a esas obligaciones sean respetados. Como señalara el Profesor MIAJA, la doctrina jurisprudencial transcrita supone la existencia de unas obligaciones cuyo sujeto activo es la humanidad entera, la comunidad internacional (17).

Por lo tanto, la sentencia de la *Barcelona Traction* reconoce implícitamente que en caso de violación de una obligación *erga omnes* (18), la relación de responsabilidad internacional que se establece no sólo es bilateral sino que se amplía a todos los Estados: cualquiera de ellos estaría autorizado para reclamar la responsabilidad del Estado al que se le impute el hecho internacionalmente ilícito.

1965, vol. 43, pp. 455 ss., reproducido en las Actas de la Conferencia de Lagonissi cit., pp. 115-140; VERDROSS, A.: "*Jus dispositivum and Jus Cogens in International Law*", A.J.I.L. 1966, 1º, PP. 55 SS.; VIRALLY, M.: "*Réflexions sur le jus cogens*", A.F.D.I. 1966, pp. 5-30; YASSEEN, M.K.: "*Réflexions sur la détermination du jus cogens*", en *L'elaboration du Droit international*, Colloque de Toulouse, société française pour le Droit international, Pedone, París 1974, pp. 204 ss.

(10) Según el primer inciso del art. 53 de la Convención de Viena de 1969, "es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de Derecho internacional general". Es evidente que lo mismo podría observarse no sólo del tratado sino también de las costumbres o actos con eficacia normativa posteriores.

(11) R. AGO, Quinto informe...cit., p. 34; en los mismos términos, la C.D.I. en su informe a la A.G. ...cit. (Documento A/31/10), p. 100.

(12) C.I.J. Recueil, 1949, p. 22 (*Affaire du détroit de Corfou-fondo*); el subrayado es mío.

(13) C.I.J. Recueil, 1951, p. 23 (*Avis consultatif, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide*); el subrayado es mío.

(14) I.C.J. Reports 1980, p. 41, par. 88. En cualquier caso, véase la reflexión sobre el carácter imperativo de los privilegios e inmunidades diplomáticos realizada en mi artículo sobre "Las obligaciones *erga omnes* en el Derecho internacional contemporáneo", R.J.E. Laley, 1985-1º, pp. 1038 ss.

(15) Opinión separada de NAGENDRA SINGH a la sentencia referida: I.C.J. Reports 1986, p. 153.

(16) C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33 (*Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase*); el subrayado es mío.

(16) Es exacta la frase del prof. JUSTE RUIZ cuando afirma que "las normas erga omnes ... constituyen la fuente principal de obligaciones jurídicas erga omnes en el Derecho internacional actual" (JUSTE RUIZ, José: "Las obligaciones erga omnes en el Derecho internacional público", Estudios de D.I. en homenaje al Profesor MIAJA de la Muela, tomo I, Tecnos, Madrid 1979, p. 227). Piénsese, por ejemplo, en la afirmación de la C.I.J. en las sentencias de 20 de diciembre de 1974 (ensayos nucleares) refiriéndose a ciertos actos unilaterales: "The unilateral statements of the French authorities were made outside the Court, publicly and erga omnes ... the international community as a whole..." (I.C.J. Reports 1974, p. 269). Es "lógico" pensar que "no todos" los actos unilaterales declaran normas de ius cogens.

(17) MIAJA DE LA MUELA, Adolfo: "El interés de las partes en el proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia", *Studi in onore di G. Morelli, Giuffrè, Milán 1975*, p. 557.

(18) Esas obligaciones erga omnes - como continuó diciendo la Corte - "découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23); d'autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel" (C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 34).

(19) Sentencia de 18 de Julio de 1966, I.C.J. Reports 1966, p. 47, par. 88.

(20) Por todos, véase un comentario de los aspectos que más nos interesan de esta sentencia en MIAJA, A., "El interés... cit.", pp. 549 ss.

(21) Como señala AGO en su quinto informe, en la memoria presentada

Bienes verdad que el *obiter dictum* de la Corte es una manifestación aislada en su jurisprudencia, pero sumamente significativa -por la reacción o giro de 180° que supone- si se piensa en la posición adoptada cuatro años antes por el mismo tribunal en los asuntos del Suroeste africano cuando se negó a admitir que en el derecho existiera una especie de *actio popularis* "o un derecho que correspondiera a todo miembro de una colectividad a ejercer una acción para la defensa de un interés público" (19). De todos modos es conocido que este previo posicionamiento de la Corte se hace en el marco de una sentencia confusa o, al menos, extremadamente técnica y apretada y adoptada con el voto dirimente del Presidente (20).

Lo importante es que, en numerosas ocasiones, la Corte Internacional de Justicia ha hecho eco de esas obligaciones "esenciales", afirmando, incluso, que todos los Estados están legitimados para reclamar su observancia; sin embargo, los tribunales internacionales (judiciales o arbitrales) nunca han decidido la aplicación de formas de responsabilidad distintas de la obligación de reparar. Ahora bien, ni los Estados se han dirigido a ellos para que decidieran sobre la aplicación de otras formas de responsabilidad (21), ni los instrumentos internacionales que instituyen esos tribunales o que prevén su jurisdicción contemplan, en su caso, otra posibilidad que la determinación de la "naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional" (22). Afirmando, como lo hizo la Corte Permanente, que "cualquier violación de un compromiso entraña la obligación de reparar" (23) o incluso que la "reparación es ... el complemento indispensable de una falta de aplicación de una convención, sin que sea necesario que ésta prevea expresamente tal consecuencia" (24), en absoluto se está diciendo a la vez que sea la única consecuencia que pudiera derivarse del incumplimiento de una norma. Y lo que nunca

ha sostenido un tribunal es que no sean posibles en Derecho Internacional la adopción -en sus justos términos- de medidas de represalia o "sancionatorias" (25) o que el contenido de la obligación violada no pudiera acarrear un régimen distinto de responsabilidad internacional.

En general, tampoco la doctrina se ha mostrado reacia a una distinta relación jurídica de responsabilidad internacional; antes bien, a partir de la segunda guerra mundial (26) y desde el final mismo de las hostilidades, en un momento en el que la imagen de los horrores que había vivido la humanidad estaban aún presente, voces tan autorizadas como las de LAUTERPACHT o JESSUP en la doctrina occidental o la de LEVIN en la soviética, coincidieron en la necesidad de distinguir dos categorías diferentes de hechos internacionalmente ilícito y de las que debían derivarse consecuencias jurídicas distintas. A partir de los años sesenta, las tomas de posición de la doctrina han sido cada vez más frecuentes y firmes, hasta representar, en las obras de nuestro tiempo -como indica Roberto AGO-, un punto de vista sólidamente apoyado y, cosa significativa, no impugnado de hecho, dibujándose una unidad fundamental de parecerse en el desarrollo de la práctica y de la teoría respecto del problema que nos ocupa (27).

3. Precisamente en 1960, en el seno de la Sexta Comisión de la Asamblea General de N.U., las delegaciones de la Unión Soviética y de otros países socialistas, criticando duramente el anteproyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados presentado por GARCIA AMADOR, especialmente por limitarse al examen de la responsabilidad por daños causados a los extranjeros (28), manifestaron que lo realmente urgente de codificar eran las reglas de la responsabilidad de los Estados por violaciones que atentan a los principios fundamentales del derecho internacional: las obligaciones relativas al

mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, la agresión y otros atentados a la integridad territorial, la independencia y la soberanía de los Estados, así como los atentados al derecho de los pueblos a su libre determinación ⁽²⁹⁾.

Debido a estas críticas, la C.D.I. tuvo que plantearse qué vía seguir en la codificación del derecho de la responsabilidad de los Estados: o continuar con la emprendida por GARCIA AMADOR, o aceptar la tesis "socialista", que hizo suya especialmente TUNKIN, o, como prefirieron otros miembros de la Comisión, codificar las reglas de la responsabilidad de los Estados en general, es decir, las reglas que establecen las condiciones de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito y sus consecuencias (reglas "secundarias"), posición que fue defendida por VERDROSS, YASSEN y, sobre todo, por AGO. A pesar de esta última la vía aceptada por la mayoría de los miembros de la C.D.I., se reconoció, como hizo el propio AGO, que la evolución producida en el curso de los últimos años en el Derecho internacional había tenido una clara incidencia en el campo de la responsabilidad de los Estados y que, por lo tanto, la Comisión también debía ocuparse de las violaciones en las que hacía hincapié la segunda vía. Según dijo entonces Roberto AGO, "hay probablemente reglas de D.I. cuya violación no comporte más que una consecuencia reparatoria, pero hay otras cuya violación comporta no solamente la obligación de reparar sino también la necesidad de una sanción de carácter represivo" ⁽³⁰⁾.

En el 15º período de sesiones (1963), los debates en la C.D.I. sobre la responsabilidad de los Estados se desarrollaron en una Subcomisión creada para estudiar el alcance del tema a la luz del nuevo planteamiento ⁽³¹⁾. Entre las cuestiones indicadas en el programa de trabajo propuesto por esta Subcomisión figuraba la siguiente: "Eventualidad de una distinción entre he-

chos ilícitos internacionales que comportan simplemente una obligación de reparar y hechos ilícitos que entrañan la aplicación de sanciones. Base posible de una distinción como ésta" ⁽³²⁾. El informe de la Subcomisión fue aprobado unánimemente por la C.D.I. y examinado, también en 1963, por la Asamblea General, todas las delegaciones que tomaron la palabra, con la excepción de los Estados Unidos de América, se mostraron de acuerdo con la vía elegida por la Comisión de Derecho Internacional para emprender el estudio de la responsabilidad de los Estados ⁽³³⁾.

Hasta el año 1976, la Comisión no abordó la elaboración de un proyecto de artículo que estableciera esa distinción. En su presentación, Roberto AGO sostuvo firmemente la necesidad de formular una distinción como ésta. Según su "quinto informe", desde el término de la segunda guerra mundial ha surgido progresivamente un convencimiento de que la violación de ciertas obligaciones cuyo respeto responde a un interés colectivo de toda la comunidad internacional no puede ser considerada y tratada como una violación "como las otras", sino que representa necesariamente un hecho internacionalmente ilícito mucho más grave, una transgresión que debe calificarse de otra manera y que implica por lo tanto el sometimiento a un régimen distinto de responsabilidad. Como pruebas directas o indirectas de ese convencimiento, el relator especial mencionó tres circunstancias que revisten, a su parecer, un significado importante: a) la distinción, consagrada en el contexto de las normas de derecho internacional, de una categoría especial de normas calificadas de "imperativas" o de *ius cogens*; b) el surgimiento del principio en virtud del cual el individuo-órgano cuyo comportamiento ha violado obligaciones internacionales de contenido determinado debe ser considerado personalmente punible, a pesar de haber actuado en calidad de órgano del Estado, y ello de conformidad con normas de

por el Reino Unido a la C.I.J. en relación con el asunto del estrecho de Corfú, la acción de Albania se definía como una "international delinquency" y en vista de las circunstancias particulares del caso, como una "offence against humanity" que agravaba seriamente la violación del derecho internacional y la "international delinquency" cometida por el Estado (C.I.J. *Mémories* 1949, p. 40, párr. 72, apartados a y b); sin embargo, la forma de responsabilidad que el Reino Unido pedía que se aplicase a Albania era únicamente la obligación de reparar (Quinto informe... cit., pp. 29-30, nota 124). Lo mismo puede comentarse de los asuntos de los rehenes norteamericanos de Teherán y de las actividades militares y paramilitares sometidos a la Corte más recientemente.

⁽²⁹⁾ Artículo 36, apartado 2º, letra d, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

⁽³⁰⁾ Véase *supra*.

⁽³¹⁾ C.P.J.I. *Affaire relative à l'usine de Chorzów* (demande en indemnité, compétence), Série A, n° 9, (arrêt n° 8), p. 21.

⁽³²⁾ Incluso se ha dado el caso (como se cita en el Informe de la C.D.I. a la A.G. cit. -Documento A/31/10-, p. 97) de que un tribunal arbitral internacional se haya pronunciado sobre la licitud de la aplicación por el Estado lesionado de una sanción, constituida en este caso por actos de represalia armada. Así se desprende del laudo sobre la Responsabilidad de Alemania por los daños causados en las colonias portuguesas de África meridional (incidente de Naulila) dictado el 31 de julio de 1928 por el tribunal arbitral instituido en virtud de los arts. 297 y 298, párrafo 4 del anexo, del Tratado de Versalles, y del laudo del mismo tribunal, emitido el 30 de junio de 1930, sobre la Responsabilidad de Alemania por los actos cometidos con posterioridad al 31 de julio de 1914 y antes de que Portugal participara en la guerra (asunto Cysne). En estos asuntos, el tribunal consideró legítima la aplicación de una sanción en forma de represalias, con la doble condición de que fueran pro-

porcionadas al hecho ilícito y que el Estado lesionado hubiera tratado previamente, sin conseguirlo, de obtener la reparación del perjuicio sufrido.

(¹⁶) Véase la actitud de la doctrina anterior a la 2ª G.M. en AGO, R., "Quinto informe... cit.", pp. 43-49.

(¹⁷) R. AGO, *Quinto informe... cit.*, p. 54; respecto de la doctrina posterior a la 2ª G.M., pp. 49-54.

(¹⁸) "Anteproyecto sobre la responsabilidad del Estado por daños causados en su territorio a la persona o a los bienes de los extranjeros". Véase el último texto revisado en *Annuaire de la C.D.I.*, 1961, vol. II, pp. 48-51 (document A/CN.4/134 et Add. 1, additif).

(¹⁹) Esta tesis fue apoyada también en 1961 y 1962 por algunas delegaciones de países del Tercer mundo: Véase Marina SPINEDI: *Les crimes internationaux de l'Etat dans les travaux de codification de la responsabilité des Etats entrepris par les Nations Unies*, Publications de l'Institut Universitaire Européen, Florencia, 1984, p. 9.

(²⁰) *Annuaire de la C.D.I.*, 1962, vol. I, p. 39.

(²¹) Dicha Subcomisión estuvo compuesta por diez miembros: AGO (Presidente), BRIGGS, GROS, JIMENEZ DE ARECHAGA, LACHS, DE LUNA, PAREDES, TSURUOKA, TUNKIN y YASSEEN (Véase la historia de esta Subcomisión en R. AGO "Premier rapport sur la responsabilité des Etats", *Annuaire de la C.D.I.*, 1969, vol. II, pp. 142 ss).

(²²) *Annuaire de la C.D.I.* 1963, vol. II, p. 238; también en el *Annuaire* 1969 cit., p. 144.

(²³) La delegación norteamericana prefería que se hubiese continuado con la línea de GARCIA AMADOR; Véase SPINEDI, M., *op. cit.*, p. 11.

(²⁴) Si bien ésta es una cuestión que no aborde el proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, Véase, en cualquier caso, A.C.D.I. 1976,

derecho penal interno particularmente severas (²⁴), y c) el hecho de que la Carta de las Naciones Unidas atribuya consecuencias especialmente determinadas a la violación de ciertas obligaciones internacionales (²⁵).

II. LA DISTINCIÓN ENTRE "CRÍMENES" Y "DELITOS" INTERNACIONALES

4. El texto del proyecto de artículo 19 que, con el título de "Crímenes y delitos internacionales", fue aprobado unánimemente por la Comisión de Derecho Internacional en su vigésimo octavo período de sesiones -1976- (²⁶), es el siguiente:

1. El hecho de un Estado que constituye una violación de una obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el objetivo de la obligación internacional violada.

2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto, constituye un crimen internacional.

3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las normas de derecho internacional en vigor, un crimen internacional puede resultar, en particular:

a) de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como la que prohíbe la agresión;

b) de una violación grave de una obligación internacional para la salvaguardia del derecho a la libre determinación colonial;

c) de una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio, el apartheid;

d) de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia y la protec-

ción del medio humano, como las que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares.

4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional conforme al párrafo 2, constituye un delito internacional.

Ante todo, dicho texto, incluido en la primera parte del proyecto de artículos dedicada al "origen de la responsabilidad internacional", se limita, lógicamente, a establecer la distinción y a definir lo que sea un "crimen internacional". Por lo tanto, la determinación de las distintas formas de responsabilidad y de los distintos sujetos autorizados a dar efectividad a esas normas, queda aplazada para una fase ulterior de la obra de codificación de la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, aunque la Comisión expresó que debía, en esa etapa, tener buen cuidado de no tomar partido con precipitación sobre temas tan delicados y complejos, deseó subrayar desde entonces que "sería absolutamente erróneo creer que existe en el derecho internacional actual un sólo régimen de responsabilidad que se aplica en general a todo tipo de hecho internacionalmente ilícito, independientemente de su mayor o menor gravedad, y de que lesione los intereses vitales de toda la comunidad internacional o simplemente los intereses de un miembro determinado de esa comunidad" (²⁷).

Por lo que respecta al concepto del párrafo 2º, la propia C.D.I. reconoció que, a primera vista, podría parecer tautológico (crimen internacional es lo que la comunidad internacional en su conjunto reconoce como crimen internacional), pero precisó que, en realidad, su enunciado no es más tautológico que la fórmula análoga del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en la que claramente inspira: "De conformidad con este artículo, una norma de derecho internacional, para que pueda 'objetivamente' ser considerada 'imperativa', o sea, como norma que no admite acuerdo en contrario, debe ser acepta-

da y reconocida 'subjétivamente' como tal por la comunidad internacional en su conjunto. Del mismo modo, el párrafo 2º del presente artículo dispone que un hecho internacionalmente ilícito para que pueda 'objetivamente' ser considerado un 'crimen internacional', sujeto como tal a consecuencias jurídicas más severas en el plano de la responsabilidad, debe ser reconocido 'subjétivamente' como 'crimen' por la comunidad internacional en su conjunto" (38).

Igualmente, de forma similar a lo observado en la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados (39), la Comisión señaló que, con la referencia a la "comunidad internacional en su conjunto", "no se trata en absoluto de exigir... un reconocimiento unánime por todos los miembros de esa comunidad y a atribuir de este modo a cada Estado un inconcebible derecho de veto. Lo que se pretende es que el carácter de 'crimen internacional' de un hecho internacionalmente ilícito dado sea reconocido no sólo por un grupo determinado (incluso mayoritario) de Estados, sino por todos los componentes esenciales de la comunidad internacional" (40).

De esta forma, en la calificación del "crimen", todos los grupos ("esenciales") de Estados existentes en la comunidad internacional han de estar de acuerdo; es decir, la mayoría (creo que cualificada) de los Estados del Norte o desarrollados, del Suro o subdesarrollados o en vías de desarrollo, del Este o bloque socialista y del Oeste, o, también, de otros grupos de Estados considerados desde diferentes perspectivas. Ahora bien, los grupos pertinentes, o que se han de tomar en consideración, dependerá de la naturaleza de cada "crimen" o de los intereses fundamentales que peligran con la violación: en el caso de una guerra de agresión tipo "Oriente Próximo", los grupos cuya convicción es necesaria para la calificación del hecho no se determinarán, por ejemplo, en función de la capacidad tecnológica o de que tengan

acceso al mar o no. En cualquier caso, creo que "todos no entendemos" con lo que se quiere decir, y lo que se quiere decir, por otra parte, supone una condición muy severa, que aunque no exija la unanimidad se acerca mucho a ella (41).

La fórmula adoptada para la definición, si tautológica o ciertamente formal, supone, un opinión de la Comisión, un criterio suficientemente claro para que pueda constituir un centro de fijación de la práctica y de la jurisprudencia internacionales y al mismo tiempo un criterio suficientemente flexible para que no suponga un obstáculo a la evolución de la conciencia jurídica de los Estados en esta materia (42). Otra posible y distinta vía que pudo elegirse, la de confeccionar una lista completa y exhaustiva de obligaciones al respecto, fue descartada por la Comisión con una serie de precisas y objetivas razones: en primer lugar, porque constituye una tarea difícilmente realizable (no hubiera sido fácil llegar a un acuerdo sobre esa lista completa); en segundo lugar, porque se hubiera visto arrastrada a definir el contenido de las obligaciones cuya violación de lugar a responsabilidad internacional (es decir, las "reglas primarias"): "la Comisión, al codificar la responsabilidad internacional, debe limitarse a tomar nota de la existencia de ciertas obligaciones internacionales que incumben a los Estados, presuponerlas y aceptarlas tal como ha sido definidas, bien por la costumbre internacional en su integridad"; en último lugar, porque la confección de la lista conduciría a un resultado rígido que, si bien podría reflejar la situación actual, no permitiría la adaptación progresiva de la norma a la evolución futura del derecho internacional y, en cualquier caso, "no sería deseable que, para poner la convención hoy adoptada en consonancia con la evolución del día de mañana, hubiera que someterla a constantes enmiendas" (43). En parecidos términos, en la codificación del derecho de los tratados y ante la pretensión de mencionar, aún a título de ejemplos,

vol. II, 1ª p. ("Quinto informe"), pp. 34-36.

(38) A.C.D.I. 1976, vol. II, 1ª p., pp. 33-34.

(39) El texto propuesto por el Ponente tenía una diferente redacción; Véase, en cualquier caso, A.C.D.I. 1976, vol. II, 1ª p. ("Quinto informe"), p. 59.

(40) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª parte (Informe de la C.D.I. a la A.G.), p. 116, par. 53.

(41) *Ibid.*, p. 118, par. 61.

(42) Como señaló el Sr. YASSEEN, presidente del Comité de redacción la frase "comunidad internacional de Estados en su conjunto" (fruto de la enmienda presentada a la Conferencia por Grecia, Finlandia y España y de su posterior vigorización por dicho Comité), no quiere decir que la norma sea aceptada y reconocida por los Estados de manera unánime, "il suffit d'une très large majorité, ce qui signifie que, si un Etat refuse isolément de reconnaître la nature impérative d'une règle, ou s'il est soutenu par un très petit nombre d'Etats, cela ne peut affecter l'acceptation et la reconnaissance du caractère impératif de cette règle para la communauté internationale dans son ensemble" (Conférence des N.U. sur le Droit des traités, Première session (1968) -A/CONF.39/11-, p. 514).

(43) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 118, par. 61.

(44) Según el ponente, Sr. AGO, "à défaut d'une telle garantie, l'introduction des notions de 'norme impérative' ou de 'crime international' ne constituerait pas un progrès réel, mais contribuerait à diviser la communauté internationale. Certains considéreraient cette garantie comme un excès de prudence; pour le Rapporteur spécial, c'est une question de sagesse élémentaire, car ce n'est qu'ainsi que la communauté internationale pourra progresser vers plus de cohésion et d'unité" (A.C.D.I. 1976, vol. I (1403ª sesión), p. 255).

(45) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª parte, p. 118, par. 61.

(43) *Ibid.*, pp. 117-8, par. 60.

(44) Véase, por ejemplo, *Conférence ... cit.*, A/CONF.39/11/Add.2 (Documents de la Conférence), p. 73.

(45) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª parte, p. 118-9, par. 63.

(46) Según la Comisión, para dar a sus propias indicaciones una base objetiva, se ha inspirado escrupulosamente en el derecho internacional actualmente en vigor y, en especial, en ciertos instrumentos convencionales -en particular, la Carta de N.U. y algunos otros tratados multilaterales- de los que precisamente se desprende que las violaciones de ciertas obligaciones internacionales están reconocidas como crímenes internacionales, así como en la costumbre internacional en la medida en que de ella se desprende un reconocimiento análogo (A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª parte, p. 119, par. 64).

(47) *Ibid.*

(48) Véase A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 119, par. 66.

las reglas imperativas más evidentes y mejor establecidas, la Comisión vino a decir que esa pretensión choca con carácter cambiante de las normas de *ius cogens* (44).

Sin embargo, a diferencia del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, el proyecto de artículo 19, junto al criterio básico del párrafo 2º y "sin perjuicio" del mismo, proporciona en el párrafo 3º, mediante una serie de ejemplos, indicaciones o aclaraciones suplementarias que permiten facilitar la comprensión y la aplicación de dicho criterio: según la Comisión -que optó por esta solución de manera unánime- el problema de la distinción entre "crímenes" y los demás hechos ilícitos es mucho más complicada que el de la distinción entre las normas de *ius cogens* y las que respecto de las cuales se admite acuerdo en contrario (45).

La lista introducida en el párrafo 3º, por lo tanto, no tiene un carácter exhaustivo, por lo que no es deducible que el derecho internacional actual no pueda ofrecer otros ejemplos de crímenes internacionales -aunque para su relación se haya basado en el derecho internacional vigente (46)- o que el derecho internacional del futuro no ofrezca otros que incluso el derecho en vigor no contemple. Ello, claramente se desprende de la redacción ("un crimen internacional puede resultar, en particular... de una violación como la que...") que utiliza esa disposición, que a la vez toma la precaución de introducir ("sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2º") que su contenido debe entenderse a la luz del criterio básico enunciado previamente; así, para determinar si, en un caso concreto, constituye un "crimen internacional" la violación de una de las obligaciones que se citan como ejemplo, o que no son citadas, habrá que proceder siempre a su confirmación en el párrafo 2º y asegurarse, por lo tanto, que la obligación concretamente violada es realmente una obligación tan esencial para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacio-

nal que su violación está reconocida como "crimen" por esa comunidad en su conjunto (47).

Para la formulación de los ejemplos, el párrafo 3º, en cada uno de sus cuatro apartados, indica primeramente una esfera determinada de normas que son esenciales para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacional, para proceder a continuación a citar una o varios ejemplos concretos de obligaciones existentes en la respectiva esfera cuyas violaciones se consideran hoy por la comunidad internacional en su conjunto como "crímenes internacionales" típicos. Y ello por reunir una doble condición: por ser obligaciones internacionales de "importancia esencial" para el logro de la finalidad fundamental que caracteriza la esfera en la que se insertan y por constituir una "violación grave" de alguna de esas obligaciones de "importancia esencial". Por lo tanto, habrá que estar a este doble requisito para los ejemplos no mencionados en cada una de las cuatro esferas o respecto de las obligaciones pertenecientes a otras esferas no citadas que se consideren esenciales para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacional.

Es evidente, como señaló la Comisión, que en cada una de las esferas mencionadas se pueden distinguir obligaciones cuya importancia para alcanzar la finalidad fundamental de que se trata es primordial y otras que sólo tienen una importancia secundaria. El incumplimiento de una de estas últimas obligaciones no puede ser tomado en consideración para acusar a una Estado de un crimen internacional. Pero, por otra parte, en el caso de las obligaciones "primordiales", no todo incumplimiento podrá calificarse de esa forma si no se demuestra la gravedad de la violación (48): ello, simplemente, es constatación de que la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales -en especial de Naciones Unidas- no considere como "crimen internacional" toda violación de una

obligación internacional esencial, sino solamente aquella que reviste una especial gravedad⁽⁴⁹⁾. Como dijo el Sr. USHAKOV en los debates de la C.D.I., un acto aislado de discriminación constituye una violación de los derechos humanos, pero no por ello es un crimen internacional; en cambio, el *apartheid* y el genocidio son crímenes internacionales porque ponen en peligro la vida de todo un pueblo⁽⁵⁰⁾. Precisamente en estos casos, y también en otros, podría hablarse, en vez de "violación grave", de "violación sistemática" o de "violación continuada"⁽⁵¹⁾.

Estas dos condiciones, pero especialmente la de la gravedad de la violación, deben conducir a la conclusión de que no toda violación de una norma de *ius cogens* internacional constituye necesariamente un "crimen" según el proyecto de artículo 19. "Si bien puede ser cierto -dijo la Comisión- que el incumplimiento de una obligación establecida por una regla de *ius cogens* constituirá a menudo un crimen internacional, no se puede negar, sin embargo, que la categoría de las obligaciones internacionales respecto de las cuales no se admite acuerdo en contrario es más amplia que la de las obligaciones cuya violación es necesariamente un crimen internacional. Una asimilación exagerada de ambos conceptos podría constituir una simplificación tentadora, pero no parece que conceptualmente sea aceptable"⁽⁵²⁾.

Ahora bien, a la inversa, ¿puede excluirse totalmente que la violación de una regla no imperativa, o de calificación dudosa, no puede constituir nunca un "crimen internacional"?⁽⁵³⁾. ¿Y en los casos de violación "sistemática", "continuada"...? Si una respuesta positiva, sin más, es improcedente, una respuesta negativa o que excluyera totalmente esa posibilidad también lo debería ser si no es fruto de un puntual estudio del caso concreto, estudio que, partiendo del proyecto de artículo 19, muy posiblemente nos llevaría a negar la existencia de un "crimen"⁽⁵⁴⁾.

El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (apartado a), la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos (b), la salvaguardia del ser humano (c) y la salvaguardia y la protección del medio humano (d), son las cuatro esferas recogidas en el párrafo 3º del proyecto del artículo 19 como resultado, según la Comisión de Derecho Internacional, del análisis de la jurisprudencia internacional, la práctica de los Estados y la doctrina más autorizada, figurando fundamentalmente entre tales esferas de normas u obligaciones las que el ordenamiento jurídico internacional contemporáneo ha elevado al rango de *ius cogens*. Huelga insistir señaló la Comisión, en la influencia determinante de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas que enuncian los propósitos y principios de la Organización⁽⁵⁵⁾.

Ahora bien, si se sigue aquel análisis, sin se tienen en cuenta las normas del *ius cogens* internacional contemporáneo y si se acude al desarrollo de la Carta de N.U. por la Declaración relativa a los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General), que en buena medida recoge esas normas de *ius cogens*⁽⁵⁶⁾, hemos de concluir, por una parte, que es cierto el carácter no exhaustivo de la lista del párrafo 3º⁽⁵⁷⁾ y, por otra, que posiblemente no es cierto que esa lista guarde un equilibrio entre las distintas esferas mencionadas si piensa en la del apartado d) y el ejemplo que recoge.

Dicho apartado hace referencia a aquellas obligaciones que tienen por finalidad la salvaguardia y protección del medio humano, citando como ejemplo típico la que prohíbe la contaminación masiva de la atmósfera de los mares. Según el Relator especial, si algunos de los otros crímenes (colonialismo, esclavitud, genocidio o *apartheid*) mencionados en los apartados precedentes están llamados a des-

(49) Véase, en este sentido, *ibid.*, p. 108, par. 34.

(50) A.C.D.I. 1976, vol. I (1374ª sesión), p. 76.

(51) En este sentido, Sr. BILGE: *ibid.* (1376ª sesión), p. 92.

(52) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2º p., p. 118, par. 62; el subrayado es mío.

(53) Para Roberto AGO, en una de sus alocuciones acerca del tema que nos ocupa, no debe excluirse esa posibilidad. Véase A.C.D.I. 1976, vol. I (1371ª sesión), p. 60, par. 21.

(54) En cualquier caso, véase mi artículo sobre "Las obligaciones ... cit." (nota 13) y su reflexión sobre el asunto de los rehenes norteamericanos en Teherán del que conocí la C.I.J.

(55) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2º p., p. 119, par. 67.

(56) En este sentido, REMIRO BROTONS, Antonio, *Derecho internacional público. I. Principios fundamentales*, Tecnos, Madrid 1982, p. 69; y GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I. y ANDRÉS SAENZ DE SANTA MARÍA, M.P., *Curso de Derecho Internacional Público*, vol. I, Servicio de Publicaciones, Universidad de Oviedo, 1983, p. 59.

(57) La R. 2625 (XXV) cita el principio de la abstención del recurso a la amenaza o al uso de la fuerza, el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales (de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia), el principio de la no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, el principio de la obligación de los Estados de cooperar entre sí, el principio de la igualdad soberana de los Estados y el principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta. Entre los ejemplos de normas de *ius cogens* citados por la doctrina se citan (Juan Antonio CARRILLO SALCEDO) los derechos fundamentales de la persona humana, el derecho de los pueblos a su libre determinación, la prohibición del recurso a la fuerza o a la

amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, y la obligación de arreglo pacífico de las controversias internacionales y, finalmente, la igualdad de status de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos que sean de jurisdicción interna de los Estados. (Soberanía... cit., p. 284), o (I. BROWNLEE) "the prohibition of aggressive war, the law of genocide, the principle of racial non-discrimination, crimes against humanity, and the rules prohibiting trade in slaves and piracy" (Principles of Public International Law, 3ª ed., 1979, Clarendon Press, Oxford 1987, p. 513). Otras relaciones de la doctrina, véase en REMIRO BROTONS, Antonio, op. cit., pp. 67-69. Véase, igualmente, supra (nota 18) y mi artículo cit., p. 1037-8.

(59) *Annuaire C.D.I.* 1976, vol. I (1403ª sesión), p. 256, par. 48.

(60) Señálese la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano (Estocolmo, 1972). En cualquier caso, véase, por ejemplo, el capítulo dedicado a la protección internacional del medio ambiente en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, L.I. SANCHEZ RODRIGUEZ y M.P. ANDRÉS, op. cit., pp. 625 ss.

(61) Véase supra, nota 36.

(62) Véase *Annuaire C.D.I.* 1976, vol. I, pp. 245 (CASTAÑEDA, par. 53), 246 (EL-ERIAN, par. 48) y 249 (NJENGA, par. 79).

(63) Véase, A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª parte, p. 120, par. 71. En la Sexta Comisión, sólo los Estados (Mongolia y México) aprobaron expresamente el ejemplo, siendo criticado, incluso, por los más firmes partidarios de la distinción (véase SPINEDÍ, op. cit., p. 56).

(64) *Annuaire C.D.I.* 1976, vol. I (1403ª sesión), p. 251, par. 10.

(65) Ante esta frase entrecortada de USHAKOV, uno podría preguntarse: ¿Y si se realizan en plena Siberia, lejos de las fronteras con otros Estados, pero causan un daño irreparable al medio ambiente, si circunscrito?

aparecer, o al menos así lo espera, por el contrario, los del apartado d) pueden ser los crímenes del futuro: privar a los seres humanos de su medio ambiente, despojarlos de sus fuentes de abastecimiento, provocar cambios climáticos, etc., (58). De esta forma, incluyendo este apartado, se ha tenido en cuenta la evolución reciente del Derecho internacional, que está prestando una particular atención a este problema a través de numerosos instrumentos multilaterales generales y regionales (59).

Bien es verdad que algunos miembros de la C.D.I. hubieran preferido, como hizo el Ponente en su anteproyecto (60), una categoría de obligaciones más amplia: la que tiene por objeto la conservación y el libre goce por todos de un bien común de la humanidad (61). Sin embargo, donde verdaderamente se produjeron reservas fue en la elección del ejemplo de la contaminación, noción que, a juicio de algunos miembros de la Comisión, no está definida con una precisión comparable a la de otros ejemplos de apartados precedentes (62). ¿Qué se entiende por "contaminación masiva de la atmósfera o de los mares"? se preguntaba el Sr. USHAKOV; ¿Se trata de la contaminación nuclear, de la petrolífera o de la bacteriológica? Es imposible saberlo -respondía- al no existir una definición de la noción de contaminación (63). Y llevaba razón el propio navío contaminaba el mar con petróleo viola la obligación de conservar un bien común de la humanidad, pero no comete un crimen internacional: en cambio, los ensayos nucleares masivos realizados por un Estado "en la proximidad del territorio de otro Estado" (64) sí pueden calificarse de "crimen internacional" (65). Ahora bien, ¿no ayuda el adjetivo "masiva" a precisar el concepto de contaminación a los efectos de la aplicación del proyecto de artículo 19? En cualquier caso, creo que el apartado d) no ha debido limitar el ejemplo de la contaminación masiva a la atmósfera y a los mares; más bien hubiera debido hablar, en general, de la biosfera (66). Por otra parte, aunque no existiese un

equilibrio entre la agresión y esta contaminación, las formas de responsabilidad no tienen por qué ser necesariamente idénticas, pero, por ejemplo, resulta pertinente afirmar que la contaminación masiva del mar es un hecho ilícito que concierne no solamente al Estado directamente perjudicado."

La esfera de obligaciones, en cambio, que no se dudó en ningún momento y respecto de la cual todos los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo al mencionarla en primer lugar, fue la relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (apartado a): como dijo la Comisión, las violaciones de tales obligaciones representan, en la conciencia jurídica de los Estados, los crímenes internacionales más graves (67). Por ello, incluso, algunos miembros de la C.D.I., al igual que el Ponente en su anteproyecto (68), pretendieron que esa categoría de obligaciones hubiese sido objeto de un emplazamiento distinto para, así, marcar la distinción entre las violaciones a las mismas y las de las demás. Según AGO, crímenes como el colonialismo, el *apartheid* y el genocidio, por mucho que repugnen a la conciencia de la humanidad, no acarrearán, para la comunidad internacional en su conjunto, las mismas consecuencias jurídicas que el crimen internacional por excelencia, esto es, la guerra de agresión (69).

Sin embargo, el ejemplo citado en el anteproyecto del Relator especial fue el de la "violación por un Estado de la prohibición de hacer uso de la amenaza o del empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", ejemplo más amplio que el finalmente elegido, la agresión (70), aunque sin perjuicio de que otras violaciones al principio fundamental del artículo 2, párrafo 4º, de la Carta de la N.U. puedan también ser consideradas como "crímenes internacionales" (71).

Por lo que se refiere al ejemplo elegido, se decidió no calificarlo con algún adjetivo porque, como señaló el

Presidente del Comité de redacción. Dr. SAHOVIC, el significado de la palabra "agresión" no es otro que el que la comunidad internacional ha dado en la "Definición de Agresión" que la Asamblea General de N.U. adoptó por consenso el 14 de diciembre de 1974 a través de su resolución 3314 (XXIX) (72). No obstante, algún miembro de la Comisión (Sr. TABIBI) hizo referencia a que "el empleo del término agresión permite cubrir los casos de agresión económica y política, agresión que es mucho más peligrosa para los países del tercer mundo que el empleo de la fuerza propiamente dicha" (73). Sin embargo, aparte de que este tipo de agresión no esté recogida en la R. 3314, la C.D.I. respondió sabiamente que no le incumbía definir el concepto exacto de agresión porque era una tarea que le correspondía a otros organismos (74).

En consideración al segundo de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, la también segunda esfera de obligaciones elegida por la C.D.I. fue la concerniente a la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos (apartado b) y como ejemplo, unánimemente acordado, la violación de la obligación que prohíbe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial (75). Ciertamente es que algunos miembros de la Comisión mencionaron la posibilidad de suprimir del ejemplo la expresión "por la fuerza", pero no insistieron ante la objeción de que con tal supresión se corría el riesgo de ampliar excesivamente el alcance de ese "crimen". En cualquier caso, según la Comisión, por la expresión "por la fuerza" debe entenderse contra la voluntad de la población sometida, aún cuando esa voluntad no se traduzca o no se traduzca todavía en una oposición armada (76).

También en consideración a otro de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta (art. 1, 3º), la tercera esfera de obligaciones (apartado c) mencionada por la Comisión en

el proyecto de artículo 19 es la referente a la salvaguardia del ser humano, si bien se señaló, aunque no como oposición decidida, la conveniencia de servirse de otra fórmula para calificar a esta esfera, precisamente de la que emplea la propia Carta y que el Relator especial utilizó en su anteproyecto: el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (77). Por otra parte, también surgieron diferencias de opinión por limitar las hipótesis de "crímenes internacionales" no sólo a las violaciones "graves" sino además a las violaciones "en gran escala": esta expresión, según se dijo, es posible que constituya una precaución excesiva (78). Sin embargo, esa precaución fue apoyada por la mayoría de los miembros de la C.D.I. ante la preocupación de una ampliación peligrosa de la categoría; además, la Comisión prefirió no apartarse de lo que, en su opinión, constituye el derecho internacional actualmente en vigor, que sólo califica de "crimen internacional" a la violación "en gran escala", es decir, a "una práctica masiva o sistemática seguida con menosprecio de los derechos y de la dignidad de la persona" (79). Por ese límite, los ejemplos elegidos fueron la esclavitud, el genocidio y el apartheid, respecto de los que la práctica internacional es clara de calificarlos de "crímenes internacionales" (80), aunque haciéndose hincapié en el carácter no exhaustivo de los mismos. Según el propio Relator especial, es evidente que existen otros "crímenes" que pueden afectarse a esta esfera de obligaciones: piénsese en la masacre de prisioneros de guerra o en la deportación de poblaciones; pero precisamente para no dar la impresión de que la lista en este apartado tenga un carácter exhaustivo es por lo que se ha preferido no indicar más ejemplos (81).

5. Por último, el proyecto de artículo 19 termina con un párrafo (el 4º) que, por medio de una expresión distinta, califica el conjunto de hechos

(69) A.C.D.I. 1976, vol. I (1374ª sesión), p. 76, par. 4.

(70) Como señaló SETTE-CAMARA, puede haber casos de polución masiva de los cursos de agua, de los lagos o incluso de ciertas partes del territorio de los Estados (Annuaire C.D.I. 1976, vol. I, -1403ª sesión- p. 249, par. 74).

(71) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 120, par. 68.

(72) Véase *supra*, nota 36.

(73) A.C.D.I. 1976, vol. I (1371ª sesión), p. 61, par. 27.

(74) Según la R. 3314 (XXIX) de la A.G. ("Definición de la Agresión"), "La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia en la presente Definición" (Art. 1).

(75) Una opinión contraria véase en BILGE: A.C.D.I. 1976, vol. I (1376ª sesión), pp. 91-92.

(76) Annuaire C.D.I. 1976, vol. I, (1402ª sesión), p. 243. Según el art. 5 de la Definición, "la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional".

(77) *Ibid.*, p. 247, par. 52. En la Sexta Comisión de la A.G., al debatirse el proyecto de art. 19, Cuba y Afganistán (Estado de la nacionalidad de TABIBI) también se expresaron de la misma forma; véase SPINEDI, *op. cit.*, p. 55.

(78) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 120, par. 68.

(79) Véase, al respecto, la intervención del Sr. BEDJAQUI en los debates de la Comisión. A.C.D.I. 1976, vol. I (1375ª sesión), pp. 84-86. Como señalan los profesores GONZALEZ CAMPOS, SANCHEZ RODRIGUEZ y María Paz ANDRES (*op. cit.*, p. 259), la idea está firmemente arraigada en la práctica de las Naciones Unidas, dado el desarrollo que en-

contró el art. 73 de la Carta en las Resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV), 2625 (XXV) y en otras muchas.

(76) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 120, par. 69.

(77) Véase este anteproyecto en nota 36. El Sr. EL-ERIAN, por ejemplo, señaló que la expresión "salvaguardia del ser humano" es demasiado vaga. Según el Sr. TABIBI, no habría ningún inconveniente para reintroducir en el párrafo c) "une référence aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, qui sont la notion de base de la Charte des Nations Unies. (Ahora bien), "comme le texte représente un compromis, il serait prêt à l'accepter sous sa forme actuelle". El propio Relator especial dijo que "l'expression 'sauvegarde de l'être humain'... lui paraît satisfaisante, puisqu'elle vise non seulement l'intégrité physique mais aussi l'égalité de dignité des êtres humains" (Annuaire C.D.I. 1976, vol. I, pp. 246, 247, y 255-6, respectivamente).

(78) En este sentido, Sr. YASSEEN, *ibid.*, p. 246. En la Sexta Comisión de la A.G., también algunos Estados (Libano y Somalia) pidieron que se suprimieran las palabras "en gran escala"; véase SPINEDI, *op. cit.*, p. 55.

(79) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 120, par. 71. Como señaló AGO, la expresión "en gran escala" "devra indiquer que la violation en question doit toucher une quantité appréciable de personnes et non pas seulement quelques individus" (Annuaire cit., p. 225, par. 45).

(80) Véase, por ejemplo, GONZALEZ CAMPOS, J.D., SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I. y ANDRES SAENZ DE SANTA MARIA, M.P., *op. cit.*, p. 260.

(81) Annuaire cit., p. 255, par. 46. En la Sexta Comisión, Israel se refirió también al terrorismo y a la toma de rehenes (Véase SPINEDI, *op. cit.*, p. 55).

(82) A.C.D.I. 1976, vol. II, 1ª parte (Quinto informe... cit.), p. 58, par. 153.

internacionalmente ilícitos que no entran dentro de la categoría especial de "crímenes internacionales": "todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional conforme al párrafo segundo constituye un delito internacional".

Independientemente de la utilidad de una disposición como ésta, cuestión que no merece mayores comentarios, la introducción de la expresión **delito internacional** no parece ser, en mi opinión, particularmente adecuada, aunque, en abstracto, tampoco creo que sea ésta una cuestión que merezca un detenimiento serio.

Para Relator especial, el término "delito" tiene la ventaja de utilizarse, en los distintos sistemas jurídicos, para designar hechos ilícitos menos graves que aquellos a que se alude con la palabra "crimen", pero, como reconoce el propio AGO, sólo habitualmente y no unánimemente; por otra parte, para el Relator, ese término ha sido utilizado comúnmente en las obras de Derecho internacional como sinónimo de hecho internacionalmente ilícito, pero, como aclara, en una época en que no se preveía aún la incorporación de una categoría especial de "crímenes internacionales" (83).

Por lo que se refiera a la denominación "crimen internacional", la Comisión señaló que optó por ella por haberse convertido en una expresión de uso corriente en la práctica de los Estados y en las obras científicas contemporáneas y que se ha utilizado con frecuencia en las resoluciones emanadas de órganos, primeramente de la Sociedad de las Naciones (83), y, luego, de las Naciones Unidas, así como en instrumentos internacionales importantes, entre otros, en la **Declaración sobre los principios y en la Definición de la agresión** y en las convenciones sobre el genocidio y el **apartheid** (84).

Sin embargo, en alguna de esas convenciones, concretamente en el Con-

venio para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948, el texto español se aparta del inglés y del francés, que utilizan el vocablo "crime". Igualmente, en el proyecto de Código "des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité" del que se está ocupando la C.D.I. se produce la sustitución del segundo término por el primero, coincidiendo, por lo tanto, las traducciones española y francesa, que a la vez difieren de la inglesa, que utiliza la palabra "offences", quizás más propia. Pero esta "guerra de la terminología" también ha llegado al proyecto sobre el tema de la responsabilidad del Estado: si el término originariamente utilizado fue el de "crimen", por las "críticas" de algunos miembros castellano-parlantes de la C.D.I. y de algunos gobiernos, en 1948, la versión española del Anuario emplea el término "delito" como el correspondiente a "crime" de las versiones francesa e inglesa (85). El más recalcitrante podría leer con estupor, por ejemplo, que si el hecho ilícito constituye un "delito internacional" se entenderá por "Estado lesionado" a todos los demás Estados. En 1985, estos recalcitrantes no muy atentos pudieron tranquilizarse con el regreso, de la traducción española, de la palabra "crimen".

Es cierto que ambos términos "crimen" y "delito", con los que hace referencia a hecho ilícitos distintos y con consecuencias agravadas en uno de los casos, no "casan" bien en Derecho español; pero, ni lo que se está debatiendo ni las cuestiones formales adquieren en Derecho internacional la relevancia que tienen en otros ordenamientos.

6. Ahora bien, en particular, la cuestión terminológica, la utilización de aquellos vocablos, ha propiciado ciertas confusiones acerca del "tipo" de responsabilidad que surge de la comisión del hecho calificado como "crimen" o del calificado como "delito"; y desde este punto de vista, la cuestión sí merece un pronunciamiento serio ante posibles desviacionismos.

En el curso de los debates de tuvieron lugar en la Sexta Comisión de la Asamblea General de N.U. sobre el proyecto preparado por la C.D.I., la mayoría de los Estados que se declararon en contra del artículo 19 argumentaron que no era oportuno prever formas de responsabilidad penal de los Estados. Como indicó el delegado de los Estados Unidos de América, promotor en el tiempo de esta opinión, en el estado actual de desarrollo del Derecho internacional, no está justificada la introducción en el proyecto de artículos de la noción de responsabilidad penal; ello hubiera requerido, como en el derecho interno, la existencia de una autoridad judicial que decida la aplicación de las penas. En la misma línea, y seguramente para quedarse tranquilo, el delegado de Portugal llegó a afirmar que el Derecho internacional en vigor no conoce la noción de crimen del Estado porque las medidas previstas en el capítulo VII de la Carta no pueden ser consideradas como sanciones penales⁽⁸⁶⁾. Incluso, en la propia C.D.I., en los debates de los primeros años de la década de los ochenta, algunos de sus miembros (SCHWEBEL y REUTER, principalmente, curiosamente nacionales de Estados que se opusieron al proyecto de artículo 19 en la Sexta Comisión) reprocharon a la disposición en cuestión tener una connotación penal o punitiva, extraña al Derecho internacional⁽⁸⁷⁾.

La raíz o fuente de esta confusión o respuesta "precautoria", como señalaron los delegados de Nueva Zelanda y España en la Sexta Comisión⁽⁸⁸⁾, fue el empleo del término "crimen". A pesar de ello, también el gobierno de España incurrió en el mismo error: en su comentario escrito al proyecto de la C.D.I., aunque no con originalidad, criticando que la Comisión no hubiese elegido el sistema de la lista completa y exhaustiva de crímenes, señaló que "había que tener en cuenta las analogías existentes entre esta materia y los derechos penales internos, en los cuales rige el principio de legalidad: *nullum crimen, nulla poena sine lege*"⁽⁸⁹⁾.

Llevaba razón el propio SCHWEBEL cuando aducía que es peligroso confundir el orden jurídico descentralizado de la vida internacional⁽⁹⁰⁾. Ahora bien, la C.D.I., en mi opinión, siempre ha tenido presente esta realidad: de los trabajos en torno al proyecto de artículo 19 no se deduce que la Comisión, en algún momento, haya tenido la intención de prever para los "crímenes" consecuencias jurídicas desconocidas en el Derecho internacional actualmente en vigor. La confusión se produce cuando las nuevas categorías se observan bajo el prisma del Derecho interno: la responsabilidad internacional derivada de la comisión de un derecho ilícito no es civil ni es penal ni va a producir la consecuencia "tipo" que el derecho interno adjudica a cada una de las distintas infracciones; se trata simplemente de una responsabilidad internacional de la que se van a derivar unas consecuencias, que pueden ser distintas en función de la violación, pero ni unas ni otras deben ser inconsecuentes con el actual grado de evolución del Derecho internacional o con un desarrollo futuro, pero posible, del mismo.

En todo caso, la existencia de una responsabilidad penal, como ha escrito Krystyna MAREK, está condicionada a la existencia de una autoridad o poder central, claramente inexistente en la sociedad internacional, una distinción entre responsabilidad penal y civil es imposible⁽⁹¹⁾. A este respecto, todavía son válidas las palabras de BASDEVANT cuando, como consejero del gobierno francés en el asunto de los fosfatos de Marruecos ante la Corte Permanente, afirmó que "el derecho penal, derecho de jerarquía y de subordinación, difícilmente puede inspirar al derecho internacional, derecho de igualdad y de coordinación"⁽⁹²⁾.

El escaso grado de institucionalización y de centralización de la sociedad internacional no es óbice para el establecimiento de una distinción como la del proyecto de artículo 19; incluso es necesaria dado el nivel de

⁽⁸⁶⁾ En su quinto informe citado (véase nota anterior), Roberto AGO señaló que esa expresión fue utilizada para calificar la guerra de agresión en el proyecto de tratado de asistencia recíproca preparado en 1923 por la S. de N. y en el Protocolo de Ginebra de 1924 sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales.

⁽⁸⁷⁾ A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 117, par. 59.

⁽⁸⁸⁾ Véase, por ejemplo, *Anuario de la C.D.I.* 1984, vol. I, pp. 274 ss. y sus correspondientes en *Anuario de la C.D.I.* 1984, vol. I, pp. 264 ss. y *Yearbook of the I.L.C.* 1984, vol. I, pp. 259 ss.

⁽⁸⁹⁾ Un espléndido resumen de estos debates y de las posiciones al respecto, véase en SPINEDI, Marina, *op. cit.*, pp. 42 ss.

⁽⁹⁰⁾ A.C.D.I. 1980, vol. I, pp. 90 ss. y A.C.D.I. 1981, vol. I, pp. 139 ss., respectivamente.

⁽⁹¹⁾ Véase SPINEDI, *op. cit.*, p. 47, nota 151 (p. 152).

⁽⁹²⁾ Documento A/CN.4/351 y Add. 1 a 3. Comentarios y observaciones de los gobiernos acerca de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos (A.C.D.I. 1982, vol. II, 1ª parte, p. 19). En el mismo sentido, véase, entre otros, René-Jean DUPUY: "Communauté internationale et disparités de développement" (*Cour général de Droit international public*), R.C.A.D.I. 1979-IV, p. 208.

⁽⁹³⁾ *Anuario de la C.D.I.* 1980, vol. I, p. 91, par. 13.

⁽⁹⁴⁾ Krystyna MAREK: "Criminalizing State Responsibility", en *Revue Belge de D.I.*, 1978-1979-2ª (vol. XIV), p. 463. Véase también al respecto, Gabriella CARELLA: *La responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, Ed. Jovene, Nápoles 1985, pp. 13 ss., y Max GOUNELLE: "Quelques remarques sur la notion de 'crime international' et sur l'évolution de la responsabilité internationale de l'Etat", en *Mélanges offerts à Paul Reuter*, Ed. Pedone, París 1981, pp. 317 ss.

(72) Publications de la C.P.J.I., Série C, n° 85, p. 1061.

(73) Opiniones muy contrarias pueden encontrarse en Prosper WEIL: "Vers une normativité relative en Droit international?", en R.G.D.I.P. 1982, n° 1, pp. 6 ss., o, por ejemplo, en R.J. DUPUY, op. cit., o en Pierre-Marie DUPUY: "Observations sur le 'crime international de l'Etat'", en R.G.D.I.P. 1980, n° 2, pp. 449 ss. Para este último autor, "tout le problème posé par l'initiative de la C.D.I. se résume dans le déséquilibre entre la norme et l'institution. L'évolution de la première conduit effectivement à dédoubler les catégories de l'illicite. Mais les insuffisances de la seconde empêcheront vraisemblablement pour longtemps le régime de cette 'responsabilité pénale' de s'établir" (p. 486).

(74) A.C.D.I. 1981, vol. II, 1ª parte (Segundo informe sobre el contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional -segunda parte del proyecto de artículos-), p. 91.

(75) Véase el Anuario hispano-luso-americano de Derecho internacional, n° 6, 1981, pp. 329-330: "Una posible aportación iberoamericana al desarrollo progresivo del derecho de la responsabilidad internacional de los Estados por hechos o actos ilícitos". Algún miembro de la C.D.I. hubiera preferido que se hablara, más que de "crimen", de violación de una obligación erga omnes (es el caso de McCAFFREY: A.C.D.I. 1983, vol. I, pp. 153 ss.).

(76) A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª parte, p. 116, par. 54.

(77) PASTOR RIDRUEJO, José Antonio: Curso de Derecho Internacional Público, 2ª ed., Tecnos, Madrid 1987, p. 509. También puede deducirse esa consideración de desarrollo progresivo del comentario escrito al proyecto de la C.D.I. presentado por el gobierno de España (Véase supra, nota 89, y SPINEDI, Marina, op. cit., pp. 49-50).

(78) Quinto informe... cit., p. 28, par. 79.

desarrollo de aquélla para asegurar más y mejor la coexistencia pacífica y la cooperación entre los Estados y para aclarar más y mejor lo que no está dispuesto a admitir la comunidad internacional en su conjunto (79). Para ello, no se busca una cobertura idéntica o similar a la existente en los ordenamientos internos: como ha dicho el tercer ponente de la C.D.I. en materia de responsabilidad del Estado, Willen RIPHAGEN, "el derecho internacional se basa en la igualdad soberana de los Estados, y, como tal, por mucho que haya sido objeto de desarrollo progresivo, no puede nunca lograr una estructura comparable a la del derecho nacional o interno". Por otra parte, "la (relativamente) nítida distinción que se hace en el marco del derecho interno entre 'normas' y 'sanciones' no puede simplemente trasplantarse al derecho internacional. En realidad, esa distinción es predicado de otra, la que existe entre una 'autoridad' central y los 'sujetos' a ella sometidos, visiblemente inexistente en la comunidad internacional de Estados" (84).

Por todas estas circunstancias y confusiones, debidas o no a la utilización de los vocablos "crimen" y "delito", quizás hubiera sido preferible que la C.D.I., al igual que el Instituto hispano-luso-americano de Derecho internacional en su XIIº Congreso, hubiese simplemente distinguido entre hechos ilícitos, por una parte, y hechos ilícitos contra la comunidad internacional, por otra (85).

7. En cualquier caso, con una terminología u otra, la distinción existe: "Es el derecho internacional general -dijo la Comisión- el que hoy distingue distintos tipos de hechos internacionalmente ilícitos y, por consiguiente, distintos regímenes de responsabilidad internacional; es, por lo tanto, dentro del marco de la codificación del derecho internacional general donde procede definir esos distintos tipos de infracciones y prever los regímenes de responsabilidad que les corresponden" (86). Ahora bien, aunque la distinción

en sí ya existía en el Derecho internacional contemporáneo -y así lo pone de manifiesto el párrafo 3º del proyecto de artículo 19 cuando al señalar ejemplos concretos de "crímenes" precisa que se hace "de conformidad con las normas de derecho internacional en vigor"- creo que lleva razón el profesor PASTOR RIDRUEJO al observar, que, junto a la codificación propiamente dicha, la distinción es, sin duda, muestra de la labor de desarrollo progresivo que lleva a cabo la Comisión de Derecho Internacional (87). No obstante, entiéndase ese "desarrollo progresivo" en sus justos términos y con la prudencia necesaria.

Por otra parte, y por todo lo que venimos afirmando, es evidente que se trata de una distinción con un alcance normativo y no puramente descriptivo. De esta forma, la diferenciación no se hace porque, desde el punto de vista teórico o didáctica, fuese útil o conveniente formular un manual de Derecho internacional público distintas clasificaciones de hechos internacionalmente ilícitos. No existe alguna razón, señaló Roberto AGO, "para hacer estas clasificaciones en el texto de una convención internacional sobre la responsabilidad de los Estados si ellas sólo tienen una justificación científica. Para que tengan razón de ser es preciso que constituya la base de una diferenciación en el plano normativo" (88). Y las formas de responsabilidad aplicables a los "crímenes" -dijo la Comisión- "difieren lógicamente" de que se aplican a otras violaciones: "también pueden ser distintos" los sujetos respectivamente autorizados a hacer efectivas esas diversas formas de responsabilidad (89).

8. A pesar de esta tímida o no contundente referencia, por parte de la Comisión, a una posible **actio popularis**, al debatirse el proyecto en la Secta Comisión de la Asamblea General, fueron pocos los Estados que se declararon en contra de ese derecho de acción; incluso, en el caso de Francia, quizás el adversario más acérrimo, con el transcurso del tiempo suavizó

su opinión. Junto con Francia, otros cinco Estados (Australia, Estados Unidos de A., Grecia, Portugal y Suecia) rechararon en un principio el conjunto de la distinción efectuada por la C.D.I. en el proyecto de artículo 19; otros, en cambio, adoptaron una posición neutral o matizada, algunos reservando su opinión definitiva a lo que finalmente se establezca sobre las consecuencias: fue el caso, entre otros, de España, Israel, Holanda, Reino Unido, R.F. de Alemania y Uruguay e incluso de Canadá, Dinamarca y Japón. Pero la gran mayoría de Estados (el grupo socialista en bloque, el del amplio tercer mundo prácticamente en bloque y significativamente Italia) apoyaron la distinción, tal y como lo habían venido manifestando años anteriores ante el anuncio de la misma ⁽¹⁰⁰⁾.

Sin embargo aunque la gran mayoría de Estados se declaró a favor, es obligado precisar que las opiniones de algunos de los que se opusieron no pueden ser ignoradas con vistas a la elaboración de una convención de codificación. Ahora bien, como señala Marina SPINEDI, en el curso de los debates, Estados que el principio adoptaron una posición neutral e incluso contraria, una vez conocieron más claramente y sin confusiones las verdaderas intenciones de la C.D.I., cambiaron de actitud. Frases como "la distinción es cada vez más evidente" (Reino Unido), "cada vez más ampliamente admitida" (Canadá)... fueron progresivamente más usuales. Incluso, la propia SPINEDI llega a la conclusión, después de analizar los distintos puntos de vista estatales entre 1976 y 1982, que sólo un Estado, Suecia, ha adoptado una posición decididamente en contra: según el gobierno sueco "la respuesta a la cuestión de saber si una obligación es esencial para la protección de los intereses fundamentales de la comunidad internacional es necesariamente subjetiva y política" y, por lo tanto, no pueden deducirse consecuencias jurídicas ⁽¹⁰¹⁾.

Una evolución similar puede decir-

se que ha experimentado, en general, la doctrina, en ocasiones, quizás, siguiendo muy de cerca y compartiendo y evolucionando a la par que los gobiernos "de casa". La doctrina española, probablemente no tan afectada, acepta ampliamente la distinción, como lo prueba particularmente lo escrito en nuestras grandes obras y manuales.

Por otra parte, es curioso constatar cómo divergencias de puntos de vista, a la postre, se toman en convergencias: algunos de los que critican la distinción enuncian, en lo que se refiere a las consecuencias, opiniones que comparten los que la defienden; y a la inversa, convergencias en cuanto a la distinción se convierten en divergencias para las consecuencias ⁽¹⁰²⁾.

También en la propia C.D.I., a partir de los primeros años de la década de los ochenta, pueden constatarse esas divergencias/convergencias en las opiniones de algunos de sus miembros: tal es el caso, ya citado, de SCHWEBEL y REUTER, posiblemente los más reacios a las nuevas categorías. Sin embargo, lo importante es señalar que en esta segunda (o tercera) época, con el nuevo Relator especial, Willen RIPHAGEN, la distinción (normativa) entre "crímenes" y "delitos" internacionales va a consolidarse, encontrando un apoyo generalizado en la C.D.I.

III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS "CRÍMENES INTERNACIONALES"

9. Ahora bien, en esta segunda (o tercera) época, cuando se han tenido que abordar las partes segunda y tercera del proyecto de artículos (es decir, las referentes al "contenido, formas y grados de responsabilidad internacional" y al "modo de 'hacer efectiva' la responsabilidad internacional y solución de controversias", respectivamente), se ha puesto claramente de manifiesto que una cosa es que la distinción

⁽⁹⁹⁾ A.C.D.I. 1976, vol. II, 2ª p., p. 115, par. 51.

⁽¹⁰⁰⁾ Sobre los debates en la Sexta Comisión de la A.G. de N.U. a partir de 1976, véase SPINEDI, Marina, *op. cit.*, pp. 42 ss., y (antes de 1976) pp. 16-17, particularmente. Puede verse también, PEDAUYE, Antonio: "Los crímenes de los Estados (Proyecto de artículo 19 elaborado por la Comisión de Derecho Internacional en materia de responsabilidad internacional)", en la R.E.D.I. 1978-1979, vol. XXXI, nº 1-3, pp. 30 ss., principalmente.

⁽¹⁰¹⁾ SPINEDI, M., *op. cit.*, p. 52.

⁽¹⁰²⁾ Como apoyo, véase SPINEDI, M., *op. cit.*, p. 2.

(105) Me refiero a los artículos 4 y 5 (Sujección a la Carta de N.U. en lo que se refiere al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y determinación del "Estado lesionado", respectivamente); véase, en todo caso, A.C.D.I. 1986, vol. II, 2ª parte, p. 41, en especial el artículo 3.

(106) Véase el Informe preliminar sobre la responsabilidad de los Estados presentado por ARANGIO-RUIZ (A/CN.4/416, 18 de mayo de 1988, pp. 3-8 -esquema de trabajo en p. 8-).

(107) Sexto informe sobre el contenido, las formas y los grados..., A.C.D.I., 1985, vol. II, 1ª parte, p. 8.

(108) Informe preliminar... de RIPHAGEN, A.C.D.I. 1980, vol. II, 1ª parte, p. 127.

(109) Véase supra.

(110) Véase A.C.D.I. 1980, vol. II, 1ª parte, p. 127.

(111) Ante un tribunal de justicia, por ejemplo, el demandado podría interponer la excepción de falta de legitimación del demandante, excepción que el tribunal (pensando sobre todo en la jurisprudencia de la C.I.J. al respecto) tendría que unir al fondo y no decidir hasta que hubiese calificado el hecho; a partir del entonces, la rechazaría o admitiría en función de la existencia o no de un "crimen" (o de la violación de una norma de *ius cogens* o no).

(112) Como ha señalado la Comisión, sólo los Estados "lesionados" tienen derecho a invocar la nueva relación jurídica (A.C.D.I. 1985, vol. II, 2ª parte, p. 127).

(113) Véase, en este sentido Tercer informe... de RIPHAGEN, por ejemplo, A.C.D.I. 1982, vol. II, 1ª parte, p. 52.

se haya consolidado y otra que la precisión de los diversos puntos del régimen de los crímenes constituya una cuestión fácil y objeto, en todos los extremos, de acuerdo. Así lo demuestra, en efecto, la labor realizada por la C.D.I. durante los siete años de Willen RIPHAGEN como Relator especial, etapa en la que los resultados obtenidos son, si cualitativos, poco cuantitativos: en 1986, la Comisión sólo había aprobado provisionalmente cinco artículos de la segunda parte del proyecto, afectando únicamente dos de ellos al régimen de los crímenes, si bien no de forma exclusiva (103). Además, es muy posible que el resultado sólo sea agua de borrajas por el distinto enfoque que el nuevo Relator especial, Gactano ARANGIO-RUIZ, pretende dar al proyecto, ahondando más en las consecuencias jurídicas de los crímenes y separándolas, por razones de mayor claridad, de las del resto de hechos internacionalmente ilícitos (104).

En cualquier caso, de los trabajos de la C.D.I. y del Derecho internacional actualmente en vigor pueden deducirse algunas aproximaciones al régimen de los crímenes que podrían centrarse en los puntos que a continuación se abordan.

10. Uno de los artículos de la segunda parte del proyecto aprobado provisionalmente por la Comisión, el número 5, establece en su párrafo 3º que "si el hecho internacionalmente ilícito constituye una crimen internacional", "para los efectos de los presentes artículos" "se entiende por 'Estado lesionado'... todos los demás Estados".

Así, en este caso, el interés lesionado no sólo es el del Estado (o Estados) sobre el (o los) que directamente se hubiera podido cometer el hecho ilícito sino el de todos los Estados que conforman la comunidad internacional "toda definición de crimen internacional en el párrafo 2 del artículo 19 -señaló RIPHAGEN- parece presuponer el reconocimiento de un interés colectivo de todos los (demás) Esta-

dos" (105). "La calificación de hecho ilícito como 'crimen internacional' parece llevar implícita una 'posición no neutral' del tercer Estado respecto del hecho ilícito" (106).

Sin embargo, como por ejemplo puso de manifiesto la sentencia de la *Barcelona Traction* (107), es evidente que ese interés colectivo y la posición no neutral del tercer Estado no sólo se circunscriben al "crimen" sino que deben deducirse también de la categoría más amplia de violaciones a normas de *ius cogens*. Nada, en cambio, se ha señalado al respecto en el proyecto, a pesar de que el propio RIPHAGEN se expresó en este sentido (108).

Hecha esta salvedad, la consideración de "lesionado", ante todo, faculta a cualquier Estado para poner en marcha o para accionar el mecanismo conducente a la calificación de las responsabilidades (109). Por otra parte, la posición no neutral del tercer Estado también considerado como lesionado le hace partícipe del régimen de responsabilidad resultante, asumiendo una serie de derechos y de obligaciones. Cae por su propio peso, de todas formas, que ese régimen será distinto respecto del Estado o Estados especial y más directamente afectados por la violación, si los hubiere, ya que en este caso el régimen generalizado tendría que completarse, para ese Estado o Estados, con las consecuencias resultantes de la comisión de un hecho ilícito "bilateral" (111).

11. Como vimos, en virtud del párrafo 2º del artículo 19 de la primera parte del proyecto, al calificación de un hecho ilícito como "crimen internacional" corresponde a la "comunidad internacional en su conjunto", lo que no significa que el reconocimiento deba ser unánime pero sí que esté apoyado por "todos los componentes esenciales de la 'comunidad internacional'". Ahora bien, es evidente que, aún así, esta afirmación es, a todas luces, demasiado abstracta.

Según Willen RIPHAGEN, esa dis-

posición presupone la existencia de obligaciones internacionales "tan esenciales (es) para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto". Por lo tanto, en su opinión, "cabe presumir que este reconocimiento es anterior a la violación" ⁽¹¹²⁾.

Estas últimas palabras de RIPHAGEN, si ciertas por vagas, en cambio pueden dar a entender que ese reconocimiento sea algo mecánico y que, cometida la violación, nada tenga que decir ya la comunidad internacional por haberse pronunciado previamente. No; es obvio que, en abstracto, la comunidad internacional en su conjunto califica como "crímenes" ciertos hechos, con independencia de que se produzcan o no; también el legislador interno prevé tipos delictivos, pero ello no excluye la necesaria intervención del juez. Por lo tanto, cometida la violación, la "comunidad internacional en su conjunto" debe reconocer que, en el caso concreto, se está ante un "crimen internacional" y ello no sólo - como señalara Roberto AGO - por quedar un margen considerable de incertidumbre en cuanto a la inclusión de un hecho en la categoría de los "crímenes" ⁽¹¹³⁾ sino especialmente por el elemental principio general del derecho de la presunción de inocencia por irrisible que en ocasiones pudiera parecer. En este sentido, el propio RIPHAGEN opinó, constatando algo evidente, que "hay pocas probabilidades de que los Estados acepten en general una norma jurídica según los delineamientos del artículo 19... sin garantías legales de que no serán acusados por otro Estado o por todos los demás Estados de haber cometido un crimen internacional" ⁽¹¹⁴⁾.

De este forma, ante un presumible crimen, siempre es necesaria la previa calificación *ad hoc*. Pero, ¿cuál es el método o procedimiento a través del cual la comunidad internacional en su conjunto califica un determinado he-

cho o situación como "crimen internacional"?

Ante todo, una concreta violación, como cualquiera de las citadas como ejemplos en el proyecto de artículo 19, puede provocar un rechazo tal generalizado en "todos los componentes esenciales de la comunidad internacional" que su calificación como crimen pudiera ser fácilmente deducible. El método, ciertamente rudimentario, no es extraño para el Derecho internacional: piénsese, por ejemplo, en la formación de la costumbre, aunque, en este caso, el proceso es mucho más lento y, por lo tanto, más seguro, pero no exento de dificultades, imprecisiones e incertidumbres; también distinto. En cualquier caso, las garantías que ofrece, incluso en los supuestos más evidentes de "crímenes", no son suficientes para ser aceptados mínimamente por los Estados, temerosos de una utilización arbitraria de la calificación obtenida por una vía como ésta. Por ello, y por lo que conlleva un "crimen", puede constatar, en la práctica, una tendencia que, como señaló la Comisión de Derecho Internacional, "reserva a instituciones internacionales distintas de los Estados la función previa de determinar la existencia de una infracción de... (las) obligaciones de importancia esencial para toda la colectividad internacional" ⁽¹¹⁵⁾.

Ahora bien, independientemente de esta reserva, la misma existencia de esas instituciones internacionales puede tener, como sucede con las costumbres generales, importantes efectos en relación con la calificación de un crimen, especialmente en el caso de la Asamblea General de N.U., órgano o "foro" en el que precisamente están presentes todos los componentes esenciales de la comunidad internacional, por lo que, a través del apoyo que se ha podido prestar a una determinada resolución, será fácil obtener lo que esta comunidad piensa acerca de un hecho ilícito. Así, por ejemplo, en su resolución 36/27, de 13 de noviembre de 1981, sobre la "Agresión armada israelí

⁽¹¹²⁾ Tercer informe... cit., p. 52, par. 138.

⁽¹¹³⁾ A.C.D.I. 1976, vol. II, 1ª parte, p. 58, par. 152.

⁽¹¹⁴⁾ Cuarto informe sobre el contenido... A.C.D.I. 1983, vol. II, 1ª parte, p. 13, par. 65. En este sentido, véase R. AGO, A.C.D.I. 1976, vol. II, 1ª parte, p. 58, par. 152.

⁽¹¹⁵⁾ A.C.D.I. 1979, vol. II, 2ª parte, p. 142, par. 12.

(116) N.U., A.G., Documentos oficiales del trigésimo sexto período de sesiones, Suplemento n° 51 (A/36/51), pp. 20-1.

(117) CARDONA LLORENS, Jorge: "La responsabilidad internacional por violación grave de obligaciones esenciales para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional (el "crimen internacional")", en *Anuario de Derecho Internacional*, vol. VIII, 1985, pp. 292-3 y nota 79.

(118) N.U., C. de S., Documentos oficiales, S/INF./36, p. 22.

(119) S/INF./37, p. 11.

contra las instalaciones nucleares iraquíes y sus graves consecuencias para el sistema internacional establecido respecto de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, la no proliferación de las armas nucleares y la paz y la seguridad internacionales", la Asamblea General condenó "enérgicamente a Israel por su acto de agresión premeditado y sin precedentes cometido en contravención de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas de conducta internacional, que constituye una nueva y peligrosa intensificación de la amenaza para la paz y la seguridad internacionales" (116). La resolución fue aprobada por 109 votos a favor, 2 en contra y 34 abstenciones.

Si en este caso el número de abstenciones parece elevado, el motivo de las mismas, como señala el profesor CARDONA LLORENS, no debe buscarse en la finalidad de la resolución sino en determinados elementos que en ellas se introducen y "que, no necesariamente, tienen que ver con el objeto de la misma": uno de los motivos que más abstenciones produjo en la resolución 36/27 fueron las frases "gravemente preocupada por el hecho de que Israel utilice ilícitamente aviones y armas suministradas por los Estados Unidos de América para cometer sus actos de agresión contra los países árabes" y "reitera su petición a todos los Estados para que de inmediato suspendan el suministro a Israel de armas y material conexo de todo tipo" (117). En todo caso, otras resoluciones de la A.G. (como la 39/50A, de 12 de diciembre de 1984, sobre la presencia ilegal en Namibia por Sudafrica, esta última aprobada por 133 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones) reflejan más claramente la convicción, por parte de la comunidad internacional esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional.

En efecto, la Asamblea General, en cuanto foro, constituye un lugar idóneo a los efectos de calificación o

declaración de un "crimen internacional" y que ofrece la garantía del tablero electrónico de recuento particularizado de votos. Es obvio, de todas formas, que habrá de estarse no sólo a los votos sino también al contenido concreto de la resolución. Pero, además, en cuanto órgano, la A.G. tiene unas competencias generales, pudiendo "discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta" (art. 10), "considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" (art. 11-1°) y "discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" (art. 11-2°), con el límite o reserva del art. 12 en favor del Consejo de Seguridad.

También el Consejo de Seguridad, primordial responsable en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, debe ser considerado como un órgano importante en el cumplimiento de esta función, más, desde luego, por los cometidos que le han asignado las Naciones Unidas que por el simple criterio de su composición. De hecho, además, independientemente de que decida o no "medidas" al respecto, el Consejo de Seguridad, con una -digamos- relativa frecuencia, ha calificado de tal forma ciertas situaciones que inducen a pensar en la existencia de un "crimen". Es el caso, por ejemplo, de la resolución 475 (1980), de 27 de junio, en la que "condena enérgicamente" al régimen racista de Sudafrica por sus premeditadas, persistentes y sostenidas invasiones armadas de la República Popular de Angola, que constituyen una manifiesta violación de la soberanía y la integridad territorial de ese país, así como una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales⁽¹¹⁸⁾, o de la resolución 487 (1981), de 19 de junio, en la que "condena enérgicamente el ataque militar del Israel (contra las instalaciones nucleares iraquíes) que viola claramente la Carta de las Naciones Unidas y las normas de comportamiento internacional" (119).

Por otra parte, el Consejo de Segu-

ridad, en una resolución tan importante como la 3314 (XXIX) de la A.G., puede decirse que encarna a la "comunidad internacional" en la determinación del crimen por excelencia: el acto de agresión. Tanto el proyecto de artículo 19 como la "Definición de la agresión" ofrecen una serie de ejemplos, precisando, de forma expresa, que la lista no es exhaustiva, y si en el primer caso se integra por la acción de la entidad "comunidad internacional en su conjunto", en el segundo se deja en manos del Consejo de Seguridad la determinación de "qué otros actos constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones de la Carta" ⁽¹²⁰⁾. Debe precisarse, de todas formas, que la acción de la "comunidad internacional" no sólo se limita a contemplar la lista sino que se dirige también a la calificación del caso concreto, coincida o no con alguno de los ejemplos citados, lo que así mismo hará el C. de S. con los supuestos de que conozca.

Puede observarse, como hizo RIPHAGEN, que "la comisión de un crimen internacional no afecta necesariamente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" ⁽¹²¹⁾, por lo que el Consejo de Seguridad tendría una intervención no generalizable respecto de todos los crímenes. Sin embargo, en la práctica, este órgano ha debatido asuntos que no directamente ponen en peligro esa paz y seguridad pero que sí se refieren a intereses fundamentales de la comunidad internacional, como por ejemplo los referentes a la política de segregación racial llevada a cabo por Sudáfrica, e, independientemente de que ello sea posible en una interpretación flexible de la Carta y del concepto "mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", bienvenida sea en todo caso una más amplia intervención del Consejo de Seguridad.

Lo importante, de todas formas, es que si el "crimen internacional" significa o implica que la comunidad internacional en su conjunto resulta lesionada, debe presumirse que la comuni-

dad internacional institucionalizada, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, tenga algo que decir al respecto y desempeñar un papel fundamental por evidente.

A pesar de ello, en ocasiones, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, el reunir el voto favorable de todos los componentes esenciales de comunidad internacional puede impedirse por factores lejanos a una convicción jurídica, aun cuando claramente se está en presencia de un crimen. Por ejemplo, y sin juzgaren absoluto el caso, con motivo de la intervención armada en Afganistán por la U.R.S.S., la Asamblea General, mediante su resolución ES/6/2, de 14 de enero de 1980, deploró "vivamente" esa intervención como incompatible con el principio fundamental del respeto a la soberanía, integridad territorial e independencia política de todo Estado, siendo adoptada por 104 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones ⁽¹²²⁾. La existencia de esos 18 votos en contra, que representaban al bloque socialista, hace que falte uno de los componentes esenciales de la comunidad internacional, por lo que, teóricamente, no hay "crimen", calificación que, previamente, tampoco pudo obtenerse en el Consejo de Seguridad ⁽¹²³⁾. Pero éste es el sistema de la comunidad internacional organizada, del que parece consciente el proyecto de artículo 19.

Ahora bien, Naciones Unidas también es la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de la Organización (art. 92 de la Carta), integrado por quince magistrados independientes que gozan de una alta consideración moral y de una reconocida competencia en Derecho, y, aunque elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad (art. 2 del Estatuto), en su elección deberá procurarse que estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo (art. 9). Por otra parte, si se tiene en cuenta la evidente relación entre los conceptos de normas

⁽¹²⁰⁾ N.U., A.G., Documentos oficiales del vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento nº 31 (A/9631), pp. 151-2.

⁽¹²¹⁾ Sexto informe... cit., p. 15.

⁽¹²²⁾ Datos recogidos de CARDONA LLORENS, J, op. cit., p. 294. Esta resolución fue adoptada en el sexto período extraordinario de sesiones de la A.G., convocado por la resolución 462 (1980), de 9 de enero de 1980, del C. de S., en el marco de la resolución 377 (V) de la A.G., a instancias de México y de Filipinas, y en la que se constataba la falta de unanimidad de sus miembros permanentes.

⁽¹²³⁾ Véase nota anterior y ALAIMO, María Luisa: "La questione dell'Afghanistan alle Nazioni Unite e il problema del consenso nell'illecito internazionale", en *Rivista di Diritto Internazionale*, 1981, fasc. 2, pp. 287-300.

(¹²⁴) O en la Convención de Viena de 21 de marzo de 1986 sobre el Derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales.

(¹²⁵) Tercer informe... cit., p. 53, par. 142.

(¹²⁶) Véase mi libro *La jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. Estudio de las reglas de su competencia*, pp. 6-7.

(¹²⁷) Véase el párrafo 2º del artículo 66 de dicha Convención, por ejemplo, en GUTIERREZ ESPADA, C., y CALVO CARAVACA, A.L., *Textos del Derecho Internacional Público*, Madrid 1986, p. 81.

(¹²⁸) Véase art. 96 de la Carta de N.U.

de *ius cogens* y "crímenes internacionales" y el procedimiento previsto en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los tratados (¹²⁴), en virtud del cual se somete a un "control jurisdiccional" las controversias que versen sobre la interpretación o la aplicación de sus artículos 53 ó 64, parece que la Corte de La Haya podría desempeñar un papel importante en la cuestión que nos ocupa. Según Willen RIPHAGEN, "la calificación de un comportamiento calificado de 'crimen internacional' con arreglo a la definición que de este concepto enuncia el párrafo 2º del artículo 19 de la primera parte del proyecto puede muy bien suscitar una controversia... (y) una controversia de esa naturaleza puede compararse perfectamente con la que puede plantearse siempre que un Estado invoca la nulidad de un tratado en virtud del artículo 53 o del artículo 64 de la Convención de Viena (*ius cogens*)" (¹²⁵).

Sin embargo, ¿cómo se interpreta, a los efectos del proyecto de artículo 19, una sentencia dada con el voto dirimente del Presidente o apoyada por una mayoría exigua de jueces?. Además, la jurisdicción de este órgano es voluntaria (lo que evidentemente podría corregirse en la "futura" Convención sobre responsabilidad) y sus sentencias, en virtud del artículo 59 del Estatuto, sólo son obligatorias para las partes en el litigio.

¿Quiere decir esto último que nunca podría obtenerse de la Corte una calificación *erga omnes*? Creo que no: Un Estado, cualquier Estado, puede solicitar de la Corte que **simplemente** declare la existencia de un "crimen"; si su competencia queda establecida (por la aceptación *ante hoc*, *ad hoc* o *post hoc* (¹²⁶) de la misma por parte del presunto autor del crimen), la sentencia sobre el fondo, en esta ocasión, trasciende de la pura relación bilateral, porque lo que debate la Corte es una conducta no del demandado hacia el demandante sino del demandado hacia toda la comunidad internacional. Si el dispositivo de la sentencia

dijera "tal Estado ha cometido un crimen internacional...", sería absurdo sostener que los derechos y obligaciones que resultan de tal calificación son únicamente ejercitables y objeto de cumplimiento por los Estados partes en el proceso seguido ante la Corte.

También la vía consultiva, junto a la contenciosa, puede ser oportuna a estos efectos, y más si se piensa, por analogía, en la reciente Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales, que prevé la solicitud de opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia en controversias relativas a la interpretación o la aplicación de sus artículos 53 o 64 (*ius cogens*), disponiéndose, además, que "la opinión consultiva que se emita... será aceptada como decisiva por todas las partes..." (¹²⁷). El modelo es ciertamente interesante; "lo malo" es que los órganos que pueden solicitar estas opiniones consultivas (¹²⁸) coinciden, precisamente, con los que creemos idóneos para la calificación del "crimen" (A.G. y C. de S.), y **non bis in dem**: si como en el caso de Afganistán citado, uno de los "componentes esenciales de la comunidad internacional" rechaza la calificación, creo que sería improcedente su posterior remisión a la Corte Internacional de Justicia; distinto es que se decida que sea únicamente este órgano judicial quien conozca del asunto.

Que subraya, por último, y como se desprende claramente, que es igualmente improcedente y totalmente incompatible con el proyecto de artículo 19, la calificación de un "crimen" hecha en el marco de instituciones regionales o parciales; no digamos las efectuadas individualmente por los Estados.

12. Una vez calificado el hecho como "crimen" por la "comunidad internacional en su conjunto", las formas de responsabilidad que resultan - como ya se ha señalado - serán, digamos, diferentes de las que se aplican a

otras violaciones; dicho de otra forma, esta nueva relación jurídica de responsabilidad internacional ya no sólo se concreta en la "reparación".

En la determinación de las consecuencias jurídicas de los crímenes, los propios órganos calificadores, especialmente el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas ⁽¹²⁹⁾, pueden desempeñar, y de hecho tienen encomendado, un papel importante y, en ocasiones, prioritario. Incluso, en determinadas circunstancias, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales puede exigir -como indicó Willen RIPHAGEN- "que por el momento no se tomen contramedidas en respuesta a un hecho internacionalmente ilícito", siendo aplicables en estas circunstancias "las disposiciones y los procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas" ⁽¹³⁰⁾. Este es el sentido del artículo 4 de la segunda parte del proyecto aprobado provisionalmente por la C.D.I., según el cual "las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado enunciadas en las disposiciones de la presente parte estarán sujetas, según corresponda, a las disposiciones y procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" ⁽¹³¹⁾.

En este terreno, la Organización de las Naciones Unidas, y en particular su Consejo de Seguridad, asume una responsabilidad primordial, o prioritaria si se quiere, previniéndose en el capítulo VII de la Carta un sistema de seguridad colectiva para los casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, sistema que se puede traducir en la decisión o en la recomendación de medidas de naturaleza diplomática, política o económica e incluso de medidas que impliquen el uso institucionalizado de la fuerza armada ⁽¹³²⁾.

Si bien este último tipo de medidas nunca han sido adoptadas por el Consejo de Seguridad, en cambio sí ha

recomendado y decidido la aplicación de las de otra naturaleza en asuntos o situaciones que afectaban, en general, al derecho a la libre determinación de los pueblos y la salvaguardia del ser humano ⁽¹³³⁾. En otro marco, también la Asamblea General ha recomendado, sea a través de una -llamémosle- resolución ordinaria, sea a través de una resolución del tipo "Unión pro paz" por la falta de unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ⁽¹³⁴⁾, medidas que afectaban a supuestos similares, incluidos aquéllos que implicaban actos de agresión ⁽¹³⁵⁾.

Interesa subrayar, en todo caso, que las intervenciones de estos órganos de N.U. no han sido todas las deseadas, sobre todo en lo que respecta al Consejo de Seguridad, quien, a causa del ejercicio del derecho de veto por parte de sus miembros permanentes, en numerosas ocasiones, y en particular en los supuestos graves de actos de agresión, se ha abstenido de "tomar partido" o adoptar las medidas previstas en la Carta ⁽¹³⁶⁾. Ahora bien, en este comentario no debe perderse de vista el hecho básico de que la Carta de las Naciones Unidas -como recuerda el profesor CARRILLO SALCEDO- no se propone tanto garantizar la aplicación del Derecho como asegurar un determinado orden, la preservación de la paz y la seguridad internacionales ⁽¹³⁷⁾.

De esta forma, no creo que corresponda a la Comisión de Derecho Internacional, en la codificación del Derecho de la responsabilidad de los Estados, proponer vías de mejora al sistema de Naciones Unidas ⁽¹³⁸⁾, debiendo limitarse a constatar lo que hay y teniendo presente que la intervención de los órganos de esta Organización no puede ir más allá de lo previsto en la Carta.

Las consecuencias jurídicas de los crímenes, sin embargo, no se circunscriben, al menos hoy, a las que se deciden o recomiendan en el marco de la comunidad internacional institucionalizada; antes bien, estas consecuencias, en la práctica de hoy, son

⁽¹²⁹⁾ Dudo que la Corte Internacional de Justicia sea un órgano idóneo para esta determinación.

⁽¹³⁰⁾ Sexto informe... cit., p. 5.

⁽¹³¹⁾ A.C.D.I. 1986, vol. II, 2ª parte, p. 41.

⁽¹³²⁾ En el proyecto presentado por RIPHAGEN, se incluye un artículo, el 15 de la segunda parte, que supone una adición al que contempla las consecuencias jurídicas generales de un crimen internacional (el 14). Según esa disposición extra, "un acto de agresión da origen a todas las consecuencias jurídicas de un crimen internacional y, además, a los derechos y obligaciones establecidos en la Carta de las Naciones Unidas en virtud de sus disposiciones" (A.C.D.I. 1985, vol. II, 1ª parte, p. 15). Sin embargo, en la C.D.I., algunos de sus miembros eran partidarios de suprimir este artículo o de refundirlo con el 14, aduciendo que una disposición expresa para los crímenes de agresión tendería a restar importancia a los demás crímenes; otros, en cambio, opinaron que un artículo 15 distinto era necesario dado que las consecuencias jurídicas de la agresión eran objeto de disposiciones específicas en la Carta de la N.U., entre las cuales figuraba el derecho de legítima defensa, reconocido en el artículo 51 de la Carta (Véase A.C.D.I. 1985, vol. II, 2ª parte, p. 25). En cualquier caso, es obvio que la intervención de N.U. y, en particular, la aplicación del capítulo VII de la Carta, no se limita a los actos de agresión.

⁽¹³³⁾ Bien es verdad que sólo en dos casos ha "decidido" la aplicación de estas medidas diplomáticas o económicas: caso de Rhodesia (Véanse, entre otras, las resoluciones 232 (1966), 253 (1968) y 277 (1970)) y de Sudafrica, aunque en este último caso más limitadamente (véase la resolución 418 (1977)).

⁽¹³⁴⁾ Resolución 377 (V) de la A.G. Según el profesor LEBEN, si la utilización de esta resolución ha sido hasta 1980, a partir de esa fecha parece que tiende a ser más frecuente: "C'est à propos de Afghanistan... que le 'renouveau' de la résolution 377 (V) s'est manifesté" (Charles LEBEN,

"Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à l'illicite dans la société internationale", en el A.F.D.I. 1982, pp. 9 ss.; en particular, p. 31 y nota 74). Véase *supra* y, sobre todo, nota 122.

(135) Es el caso, por ejemplo, de la resolución 36/27 antes citada (véase *supra* y nota 116).

(136) Véase, por ejemplo, e interprétese también, la resolución 573 (1985) adoptada por el C. de S. tras el bombardeo por Israel de la sede de la O.L.P. en Túnez. Dicha resolución, adoptada por 14 votos a favor con la abstención de los EE.UU. de A., contenía, entre otros, el siguiente punto: "Urgently request the States Members of the United Nations to take measures to dissuade Israel from resorting to such acts against the sovereignty and territorial integrity of all States" (recogida del I.L.M., 1985, n.º 6, pp. 1740-1).

(137) CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, *Curso de Derecho Internacional Público*, Departamento de Derecho Internacional público, Universidad de Sevilla, 1988, p. 181 (edición policopiada).

(138) En especial -como ha indicado RIPHAGEN- habida cuenta de la existencia del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización (*Tercer informe... cit.*, p. 53, nota 141).

(139) *Tercer informe... cit.*, p. 52, par. 136. Igualmente, véase *supra*.

(140) Véase el texto de esas disposiciones en A.C.D.I., 1985, vol. II, 1.ª parte, pp. 9-10.

(141) *Sexto informe... cit.*, p. 14, nota 44. Al respecto, el actual Ponente, Sr. ARANJUNO-KOZY, ha señalado que "si bien es posible que todas las clases de consecuencias de un hecho ilícito establecidas muy sumariamente también, tal como están formuladas, a los crímenes, ello ciertamente no es así" (*Informe preliminar... cit.*, p. 5).

(142) En este sentido, véase RIPHAGEN, *Cuarto informe... cit.*, p. 12.

casi excepcionales. Pero al igual que respecto de éstas, aquellas otras consecuencias jurídicas de los crímenes internacionales, y así se deduce de los trabajos de la C.D.I., no deben ser inconsecuentes -como dijimos más arriba- con el actual grado de evolución del Derecho internacional o con un desarrollo futuro, pero posible, del mismo.

Ante todo, la comisión de un crimen puede afectar, más directa y especialmente, a un determinado Estado o Estados. "Conviene no pasar por alto -señaló el anterior Relator especial- que en muchos casos de crimen internacional, aunque no en todos, el mismo comportamiento constituye también un hecho internacionalmente ilícito bilateral, es decir, que en muchos casos hay uno o varios Estados especialmente perjudicados por la violación en lo que se refiere a los derechos de esos Estados siguen siendo determinadas por las normas relativas a otros hechos internacionales ilícitos" (139).

Consecuentemente, el primer párrafo del artículo 14 de la segunda parte del proyecto presentado por Willen RIPHAGEN, artículo que recoge en general las consecuencias jurídicas de los crímenes, comienza afirmando que "un crimen internacional da origen a todas las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito y, además,..."; es decir, aparte de las consecuencias propias de los crímenes, dará lugar a una reparación.

Sin embargo, de esa segunda parte del proyecto, y particularmente de sus artículos 6 y 7, parece deducirse que de esa "reparación" participan también el resto de Estados (140). Entendiendo la reparación en un sentido amplio, es cierto que cualquier Estado, y no sólo el más directamente lesionado, puede exigir el autor del crimen que ponga término a la violación y que suministre las garantías apropiadas contra la repetición del hecho. Ahora bien, ¿puede participar de una reparación en su sentido más propio?

Tal y como está redactado el artículo 6 citado, es procedente afirmar que el "Estado lesionado (es decir, "todos los demás Estados" según el proyecto del artículo 5) podrá exigir al Estado que haya cometido (el crimen)... que restablezca la situación que existía antes del hecho", o lo que es lo mismo, que proceda a un *restitutio in integrum*. Por otra parte, creo que cualquier Estado puede exigir igualmente del autor que proporcione (y también que le proporcione), de una u otra forma, una satisfacción. Pero lo que no pienso que sea procedente es, como claramente se infiere de los artículos 6, párrafo 2, y 7 en relación con el 5, que cualquier Estado, por la comisión de un crimen, exija del autor "que le pague una suma de dinero". Bien es verdad que en un comentario de RIPHAGEN al proyecto, aunque en nota, se señala que "obviamente, la obligación del Estado autor de pagar 'una suma de dinero correspondiente al valor que tendría el restablecimiento de la situación que existía antes de la violación' (art. 6, parr. 2), puede aplicarse únicamente un pago hecho al Estado o Estados que han sufrido de hecho daños susceptibles de compensación mediante ese pago". "No obstante -continúa diciendo acertadamente- cada Estado que no sea el Estado que ha cometido el crimen internacional tiene derecho a exigir que tal pago se haga a ese Estado o Estados" (141).

Con estas primeras consecuencias no sería apresurado concluir ya que el principio general de Derecho internacional relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, no se aplica a los casos en los que se ha cometido un crimen internacional (142), inaplicación que igual y obviamente se desprende de las consecuencias jurídicas de los crímenes, consecuencias a las que, por otra parte, RIPHAGEN califica de "adicionales" (143).

Según este Relator especial, uno de los tipos de estas consecuencias jurídicas adicionales constituye una aplicación del principio de que todos los

Estados distintos del Estado autor deben a ejercer un cierto grado de solidaridad cuando se vean confrontados a la comisión de un crimen internacional ⁽¹⁴⁶⁾. Por lo tanto, Una consecuencia jurídica del crimen es que crea obligaciones de solidaridad con todos los demás Estados y entre ellos ⁽¹⁴⁵⁾, y, aunque -según RIPHAGEN-, tanto la naturaleza como la organización puesta en práctica de esas medidas de solidaridad son susceptibles de determinación por la comunidad internacional en su conjunto, no obstante, puede reconocerse un mínimo de solidaridad necesaria aplicable en todos los casos de comisión de un crimen internacional; pues bien, este mínimo, en lo que respecta a la naturaleza de las nuevas obligaciones, se indica en el párrafo 2º del proyecto de artículo 14 ⁽¹⁴⁶⁾ con el siguiente tenor literal:

"Un crimen internacional cometido por un Estado crea para todos los demás Estados la obligación:

- a) de no reconocer la legalidad de la situación originada por ese crimen;
- b) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido tal crimen para mantener la situación originada por ese crimen; y
- c) de unirse a otros Estados para prestar asistencia mutua en la ejecución de las obligaciones enunciadas en los apartados a y b" ⁽¹⁴⁷⁾.

Este último apartado, máxima expresión de esa solidaridad, tiende a hacer más efectivas las "medidas" recogidas anteriormente: de la del apartado a) ⁽¹⁴⁸⁾, estrechamente ligada a la sanción de nulidad de los tratados, costumbres o actos con eficacia normativa en oposición a una norma de *ius cogens* y la que hay que deducir asimismo la inoponibilidad *erga omnes* de la situación contemplada, y, la del apartado b), dirigida -como señala RIPHAGEN- al "autor" del crimen, por cuanto "prohibe la cooperación internacional con el Estado autor en la medida en que esa cooperación ayuda al Estado autor a mantener la situación

originada por el crimen"; en cambio, esa prohibición "no comprende desde luego la cooperación internacional con el Estado autor en esferas que no guarden ninguna relación con el crimen internacional ni con la situación originada por ese crimen" ⁽¹⁴⁹⁾.

Más sucintamente, otro de los tipos de consecuencias jurídicas "adicionales" se recoge en el segundo y último inciso del párrafo 1º del proyecto de articulo 14 al establecer que "un crimen internacional da origen a... los derechos y obligaciones que determinen las normas aplicables aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto".

Si la redacción de este inciso puede aparecer algo, digamos, peculiar, de peculiar pasaría a confusa si se interpreta de acuerdo al comentario que el Relator especial hizo del mismo: según RIPHAGEN, este tipo de consecuencias adicionales "sólo pueden determinarse por la comunidad internacional en su conjunto siempre y cuando ésta reconozca determinados hechos... como constitutivos de crímenes internacionales. En consecuencia, el párrafo 1 del presente artículo hace referencia a 'las normas aplicables aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto' " ⁽¹⁵⁰⁾. Es decir, este nuevo tipo de consecuencias serían aquellas que, en cada caso, una vez calificado el hecho ilícito como crimen, determinara la comunidad internacional en su conjunto.

No, se rompería el esquema, a no ser que la disposición se refiera a las medidas adoptadas, fundamental y prácticamente, en el marco de la comunidad internacional institucionalizada, más no creo que, específicamente, sea así ⁽¹⁵¹⁾.

Independientemente de ese comentario, la expresión utilizada en el párrafo transcrito es, como reconocieron algunos miembros de la C.D.I., demasiado vaga, debiendo ser sustituida por otra más clara; concretamente, ese inciso podría hacer referencia a "los derechos y obligaciones que determi-

⁽¹⁴³⁾ Véase Sexto informe... cit., p. 14.

⁽¹⁴⁴⁾ Ibid., pp. 14-15.

⁽¹⁴⁵⁾ Véase Cuarto Informe... cit., p. 13, par. 62.

⁽¹⁴⁶⁾ Véase Sexto informe... cit., p. 15.

⁽¹⁴⁷⁾ Véase el art. 6-1º propuesto por RIPHAGEN en su tercer informe, redactado en los mismos términos (A.C.D.I. 1982, vol. I, p. 210 o Tercer informe... cit., p. 56). En cualquier caso, en la C.D.I., por lo que respecta al párrafo 2º del art. 14, se señaló que, incluso como expresión de una obligación mínima de solidaridad, el párrafo debía referirse a deberes más activos de todos los Estados distintos del Estado autor. Concretamente, se mencionó el deber de cooperación de esos Estados con respecto al enjuiciamiento y castigo del autor de un crimen internacional (A.C.D.I. 1985, vol. II, 2ª parte, p. 25).

⁽¹⁴⁸⁾ Este apartado se inspira claramente en la regla enunciada en la Declaración sobre los principios (R. 2625-XXV- de la A.G.) según la cual "no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza".

⁽¹⁴⁹⁾ Tercer informe... cit., pp. 57-8.

⁽¹⁵⁰⁾ Sexto informe... cit., p. 14.

⁽¹⁵¹⁾ Téngase en cuenta, además, el párrafo 3º de este proyecto de artículo 14, que establece: "Salvo que una norma aplicable de derecho internacional general disponga otra cosa, el ejercicio de los derechos dimanantes del párrafo 1 de este artículo y el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los párrafos 1 y 2 de este artículo están sujetos, *mutatis mutandis*, a los procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales". Sin embargo, según RIPHAGEN, la función de este párrafo 3º es completamente diferente de la del art. 4 citado *supra*, porque "la comisión de un crimen internacional no

afecta necesariamente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" (Sexto informe... cit., p. 15). A mi manera de ver, en cambio, parece más bien una cláusula no muy necesaria dado el artículo 4.

(152) Algunos otros miembros de la Comisión, sin embargo, preferían la fórmula o expresión empleada por el Relator especial: A.C.D.I. 1985, vol. II, 2ª parte, p. 25.

(153) Sobre la licitud de estas medidas puede hacerse referencia al laudo arbitral de 9 de diciembre de 1978 relativo a los servicios aéreos entre los Estados Unidos de América y Francia, laudo en el que el Tribunal sostuvo que "en el estado actual del Derecho internacional general, y salvo que compromisos específicos derivados de tratados particulares y especialmente de los sistemas instituidos en el marco de las Organizaciones internacionales digan otra cosa, todo Estado puede valorar por sí mismo su situación jurídica respecto de los demás Estados. En presencia de una situación que a su juicio implique la violación de una obligación internacional por otro Estado, puede, con sujeción a lo dispuesto por las reglas generales del derecho internacional relativas al uso de la fuerza armada, decidir la aplicación de "contramedidas" distintas a asegurar el respeto de su derecho" (par. 81 del laudo, *Recueil des sentences arbitrales*, vol. XVIII, pp. 482 ss., recogido de CARRILLO SALCEDO, J.A., op. cit., p. 241; más ampliamente véase en GUTIERREZ ESPADA, C. y CALVO CARAVACA, A.L.: *Textos de Derecho Internacional Público*, ed. Tecnos, Madrid 1986, pp. 150 ss.). Creo, en todo caso, que las líneas citadas, especialmente las del último inciso, deben interpretarse en sus justos términos: esas "contramedidas" están condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos y no exclusivamente al señalado (véase nota siguiente).

(154) Estas condiciones, respecto de las "represalias", son, en general: 1) que el Estado lesionado haya intentado previamente obtener una "reparación"; 2) que exista proporcionalidad entre la medida adoptada y la violación previa; 3) que no implique el uso de la fuerza, salvo legítima defensa.

nen las normas aplicables de derecho internacional (152).

En todo caso, sea lo que sea, es evidente que, por una parte, la entidad "comunidad internacional en su conjunto", al calificar el hecho, puede a la vez determinar sus consecuencias, y que, por otra, existen consecuencias jurídicas aplicables a los crímenes que el Derecho internacional contempla. A este respecto, debe tenerse en cuenta el proyecto de artículo 3 (segunda parte) según el cual "... las reglas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado que no estén previstas en las disposiciones de la presente parte".

Ante todo, el Estado o Estados especial y más directamente lesionados, si los hubiere, pueden adoptar las medidas de "autotutela" previstas por el Derecho internacional (153) teniendo presente las condiciones que, al respecto, este mismo Derecho exige (154). En particular, según el artículo 9, párrafo 1º, de la segunda parte del proyecto y con sujeción a ciertas limitaciones (155), "el Estado lesionado podrá, como medida de represalia, suspender el cumplimiento de (las obligaciones contraídas con el)... Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito" (156).

¿Y los demás Estados?, ¿pueden, con las mismas limitaciones, decidir unilateralmente la aplicación de esas medidas de represalia? Como se ha señalado más de una vez, si el hecho ilícito constituye un crimen internacional, por "Estado lesionado", en virtud del art. 5 del proyecto se entenderá "todos los demás Estados", por lo que cualquier Estado "podrá" adoptar (entre otras) la medida de represalia citada con las limitaciones que contiene.

En mi opinión, ésta es la cuestión más difícil del tema que nos ocupa, "le noyau dur". Si es cierto que la comisión de un crimen internacional debe considerarse como una infracción co-

metida contra todos los miembros de la colectividad internacional, y no sólo, en caso de que los hubiere, contra el Estado o Estados más directamente afectados, lleva razón Roberto AGO cuando aduce que "no se pueden subestimar los riesgos que crearía el hecho de llevar el reconocimiento de ese principio -cuyo valor estriba sobre todo... en afirmar la necesidad de una solidaridad en general frente... (a esos atentados)- hasta el extremo de considerar que todo Estado está automáticamente autorizado a reaccionar contra la violación de ciertas obligaciones cometidas en perjuicio de otro Estado y a aplicar individualmente al Estado autor de la violación medidas de represión. Por ello, es comprensible que una colectividad como la internacional, dedicada a la búsqueda de una organización más estructurada y de un esbozo, por lo menos, de 'institucionalización', haya tomado otra dirección, es decir, se haya inclinado hacia un sistema que reserva a instituciones internacionales distintas de los Estados la tarea previa de (la calificación)... y, después, de tomar una decisión acerca de las medidas que deban adoptarse y de su ejecución" (157).

Ahora bien, siembre es posible, como lo demuestra la práctica, que falte una "decisión" colectiva al respecto. Piénsese, además, en el supuesto, nada insólito, de que el Estado autor del crimen persista en la violación y se niegue a dar la mínima satisfacción. ¿El crimen, en este caso, debe quedar impune?

Cualquier Estado, ante todo, puede decidir unilateralmente las medidas de retorsión (158) que estime convenientes, medidas que, siendo lícitas, pueden adoptarse respecto de todo acto ilícito pero que, sin embargo, no por ello deben ser consideradas como irrelevantes si van dirigidas al autor de un crimen. Es evidente que si un número considerable de Estados, aún unilateralmente, aplican este tipo de medidas, aún con distinto contenido, los intereses del Estado a quien se le imputa el crimen se verán seriamente

afectados. ¿Motivo de enmienda?

¿Motivo para que, si no hay ánimo de enmienda, se procediera a la adopción de medidas más graves como las de "represalia"? No -podría responderse-, un Estado no puede asumir por sí sólo la función de "gendarme" de la comunidad internacional... el remedio sería peor que la enfermedad... el caos al que podría conducir una abierta permisividad en este sentido no conviene a la comunidad internacional ni a su ordenamiento jurídico ⁽¹⁵⁹⁾.

A falta de una "decisión" de la comunidad internacional en su conjunto, si se rechaza la adopción unilateral de medidas de represalia, creo que debiera pensarse en la conveniencia (y en la licitud) de una respuesta semicolectiva.

En este sentido, para RIPHAGEN, supone una garantía que las contramedidas sean "adoptadas por una agrupación de Estados colectivamente... La idea en sí no carece enteramente de precedentes, aparte de la circunstancia de que incluso un crimen internacional puede afectar a algunas partes de comunidad internacional más que otras ⁽¹⁶⁰⁾. Además, la propia "comunidad internacional en su conjunto podría reconocer que, en determinadas circunstancias, sería más apropiado ocuparse del asunto únicamente en el plano regional" ⁽¹⁶¹⁾.

De hecho, con motivo de la crisis de los rehenes norteamericanos en Teherán, y ante el velo interpuesto por la U.R.S.S. a un proyecto de resolución presentado al Consejo de Seguridad de N.U. que contemplaba la imposición de "sanciones" económicas a la República islámica de Irán, la Comunidad Económica Europea, por medio de una declaración adoptada en Nápoles el 17 de mayo de 1980 por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Miembros, decidió aplicar las medidas previstas en el proyecto de resolución citado; en particular, todos los contratos concluidos desde el 4 de

noviembre de 1979 serían afectados por medidas de embargo ⁽¹⁶²⁾.

En éste y en algún otro caso ⁽¹⁶³⁾, ¿se actúa fuera de la cobertura del Derecho internacional? Si existe una previa calificación como "crimen" por la comunidad internacional en su conjunto, creo que no.

Al respecto y con las salvedades necesarias ⁽¹⁶⁴⁾, creo que es oportuno señalar que, en caso de "ataque armado", también es una respuesta semicolectiva, y lícita, la legítima defensa "colectiva" si es llevada a cabo de conformidad a la Carta de N.U., instrumento que, por el contrario, no da pie en mi opinión a que, en ese caso, cualquier Estado, individualmente y remitiéndose a su propia apreciación, pueda repeler la agresión; como ha señalado la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 27 de junio de 1986, "no existe en derecho internacional consuetudinario alguna regla que permita a otro Estado ejercitar el derecho de legítima defensa colectiva remitiéndose a su propia apreciación de la situación" ⁽¹⁶⁵⁾: "...en derecho internacional consuetudinario... ninguna regla permite la puesta en práctica de la legítima defensa colectiva sin el requerimiento del Estado que se juzgue víctima de una agresión armada" ⁽¹⁶⁶⁾.

Por otra parte, junto a las medidas colectivas que los Estados pueden adoptar conforme al Derecho internacional general, aprovechando o no el foro de una Organización internacional, existen otras, de indudable relevancia para el tema que nos ocupa, decididas por los órganos competentes de las Organizaciones internacionales y de acuerdo al respectivo Derecho particular, que afectan al disfrute de los derechos inherentes a la calidad de Estado miembro. En efecto, un gran número de tratados instituyentes contemplan la posibilidad de que, por la violación de ciertas obligaciones internacionales relacionadas o previstas con o en los mismos, pueda procederse a la suspensión de alguno o de todos los derechos

⁽¹⁵⁵⁾ Estas limitaciones están recogidas en los arts. 9-2º y 10 a 13. Una de esas limitaciones (art. 10-1º) se refiere al previo agotamiento de los procedimientos de arreglo pacífico, no distinguiéndose entre crímenes y delitos. Sin embargo, en los debates que tuvieron lugar en la Sexta Comisión de la A.G. de N.U. durante 1976 y 1982 sobre el proyecto preparado por la C.D.I., se hizo referencia a que, en el caso de la comisión de un crimen, el Estado lesionado tendría la facultad de adoptar inmediatamente medidas de represalia sin necesidad de solicitar previamente la reparación; significativamente, ésta fue la opinión de Estados Unidos (véase SPINEDI, M., op. cit., pp. 63-65).

⁽¹⁵⁶⁾ En especial, una de esas limitaciones, recogida en el art. 12 del proyecto, hace inaplicable la medida respecto de las obligaciones de los Estados en virtud de una norma imperativa de Derecho Internacional general. Por esta razón, en el caso de la comisión de un crimen, no sería aplicable el art. 8 del proyecto en virtud del cual "... el Estado lesionado podrá, como medida de reciprocidad, suspender el cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado que haya cometido un hecho internacionalmente ilícito, si tales obligaciones corresponden a la obligación violada o están directamente relacionadas con ella". Véase *supra* la relación entre normas de ius cogens y crímenes internacionales. Señálese, por otra parte, que en el quinto informe presentado por RIPHAGEN (A.C.D.I. 1984, vol. II, 1ª p., p. 3), los arts. 8 y 9 del proyecto hacían referencia a que el Estado lesionado **tendrá derecho**, expresión que en el sexto informe cit., (p. 11) se sustituye por la palabra **podrá**.

⁽¹⁵⁷⁾ Octavo informe... de R. AGO, A.C.D.I. 1979, vol. II, 1ª p., p. 43.

⁽¹⁵⁸⁾ Entiéndase por **retorsión** aquel acto ilícito, pero inamistoso, dirigido a causar daño al Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito.

⁽¹⁵⁹⁾ A este respecto, la posición mantenida por RIPHAGEN ha sido muy restrictiva. Algunos miembros de la C.D.I., sin embargo, opinaron que todos los Estados, individualmente,

pueden adoptar "contramedidas" respecto del autor del crimen; ahora bien, lo que no resulta claro de estas opiniones es si se referían a las medidas de represalia o sólo a las de retorsión (véanse, en particular, las opiniones de SCHWEBEL (A.C.D.I. 1980, vol. I, pp. 90-3) y SINCLAIR (A.C.D.I. 1983, vol. I, pp. 140-3)).

(109) Tercer informe... cit., pp. 53-4.

(161) Sexto informe... cit., p. 15.

(162) Véase Charles ROUSSEAU: "Chronique des faits internationaux", R.G.D.I.P., t. 84, 1980, n.º 3, pp. 883-4. Sobre la comisión de un "crimen internacional" por el Estado de la R.I. de Irán, véase mi artículo sobre "Las obligaciones erga omnes..." cit., pp. 1038 ss.

(163) Me refiero a las medidas adoptadas por la C.E.E. respecto de Argentina con motivo de la crisis de las Malvinas: Véase "Chronique des faits..." cit., R.D.G.I.P., t. 86, 1982, n.º 4, p. 748.

(164) La legítima defensa, ¿es una forma de responsabilidad? La respuesta de la C.D.I. parece afirmativa: véase al respecto, como resumen, SPINEDI, M., op. cit., pp. 84 y 40 especialmente.

(165) Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, I.C.J. Reports 1986, p. 104, par. 195.

(166) Ibid., p. 105, par. 199. En particular, y aunque anterior a esta sentencia, sobre la legítima defensa en relación al tema que nos ocupa, es interesante ver CARELLA, G.: La responsabilità dello Stato per crimini internazionali, Jovene, Nápoles, 1985.

(167) Artículos 5 y 6. Véase el art. 19 para el caso de incumplimiento de las obligaciones financieras para con la Organización.

(168) Artículo 8. Véase art. 9 para el caso de incumplimiento de las obligaciones financieras para con la Organización.

del Estado miembro o incluso a su expulsión de la Organización. En particular, y en lo que pudiera afectar a las consecuencias jurídicas de los crímenes, la Carta de las Naciones Unidas recoge este tipo de medidas de carácter disciplinario para los casos en los que "haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta" (167). Por su parte, por ejemplo, el Estatuto del Consejo de Europa prevé en caso de infracción grave de las normas sobre derechos humanos y libertades fundamentales (168).

Pues bien, todas estas medidas distintas a las de contenido reparatorio que, en virtud del Derecho internacional contemporáneo, pueden ser afectadas a la comisión de un crimen internacional, ¿deben ser calificadas como "sanciones"?

Si en un primer momento el término utilizado por la C.D.I., y especialmente por Roberto AGO, fue el de sanción, a raíz de la discusión de 1979 del artículo 30 de la primera parte del proyecto (169) dicho término fue sustituido por el de "contramedidas", mutación que, sin implicar un cambio en los puntos de vista de la C.D.I. sobre las consecuencias jurídicas de los crímenes, fue debida, como preciso la Comisión, a "la tendencia que se manifiesta en el Derecho internacional contemporáneo a reservar la aplicación de la palabra 'sanción' para las medidas de reacción aplicadas en virtud de una decisión tomada por una organización internacional a consecuencia de una violación de una obligación internacional que tiene graves consecuencias para toda la comunidad internacional, especialmente ciertas medidas que las Naciones Unidas están autorizadas a adoptar, dentro del marco del sistema previsto por la Carta, con miras al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" (170).

Sin embargo, años antes, en 1973, la C.D.I. había definido puntualmente a la sanción como aquella "medida que, sin implicar necesariamente el

uso de la fuerza, se caracteriza -parcialmente al menos- por el hecho de tener como finalidad infringir un castigo. Tal finalidad no se identifica, por tanto, con la acción coercitiva encaminada a lograr la ejecución de la obligación, la reintegración del lesionado o la reparación de los daños" (171).

Así, en el caso de la declaración de Nápoles, es decir, en el caso de una Organización internacional aunque no de N.U., las medidas adoptadas no puede afirmarse que fuesen sanciones o contramedidas (o medidas) "represivas" porque, como se subrayaba, tenían "por único objetivo acelerar la liberación de los rehenes" (172). En este caso, por lo tanto, la Comunidad Europea decidía una acción "coercitiva", no destinada a infringir un castigo (lo que muy posiblemente no le correspondía). Pero también en el caso de las medidas decididas o recomendadas por Naciones Unidas, la finalidad de muchas de ellas ha sido expresamente el cumplimiento de la obligación de cesar en la actividad (173), por lo que difícilmente se las podría calificar de sanciones o de medidas represivas. Por lo tanto, habrá que estar a cada caso concreto y ver o interpretar la finalidad que persigue la resolución que indica las medidas.

En cualquier caso, estoy de acuerdo con el nuevo Relator especial, Gaetano ARANGIO-RUIZ, cuando prefiere el término "medidas" al de "contramedidas": "Uno de los motivos por lo que nos sentimos renuentes a aceptar el término 'contramedidas': 'Uno de los motivos por lo que nos sentimos renuentes a aceptar el término "contramedidas" es que podría confundir la noción... de que el propio hecho ilícito no puede calificarse de medida. Aunque bien podría suceder que el Estado infractor catalogara de conducta ilícita de medida (o incluso de contramedida), adoptada como reacción ante su supuesto hecho ilícito del Estado o Estados lesionados, sería más acertado que el 'legislador' no empleara ningún lenguaje que pudiese

alentar a que se catalogara un hecho ilícito de otra cosa que no fuera un hecho o una acción ilícita. Otra razón de nuestra renuencia es la sensación de alarde de poder que despierta el término 'contramedidas' " (174).

13. En otro orden de ideas, es evidente que la interpretación o la aplicación de las disposiciones de la "futura" convención que afecten a los crímenes internacionales podrán (o tendrán que) suscitar controversias, controversias que irán referidas tanto a la cuestión de si ante un caso concreto nos encontramos en presencia de un crimen como a la del incumplimiento de las obligaciones precedentes o a la de la licitud de las medidas que han podido ser adoptadas al respecto.

En el primer caso, las controversias versarían sobre la interpretación o la aplicación del actual proyecto de artículo 19 y, principalmente, podrían plantearse en los siguientes términos: ¿tal hecho ilícito constituye un crimen? El procedimiento que le diese "solución" no podría ser cualquiera de los previstos por el Derecho internacional. Dicho de otra forma, esta controversia implica la calificación del hecho, calificación que no puede hacerse más que conforme a lo previsto en el propio artículo 19. Así, aunque el Relator especial, Willen RIPHAGEN, había anunciado su propósito de incluir en la tercera parte del proyecto (Modo de "hacer efectiva" la responsabilidad internacional y solución de las controversias) una disposición que previera el sometimiento a la C.I.J. de las controversias relativas al artículo 19 (175), lo cierto es que el proyecto de esa tercera parte presentado por el propio RIPHAGEN nada se dice acerca de ese artículo. Bien es verdad que, aún calificado oportunamente el hecho, siempre pueden existir dudas o quedar un margen de incertidumbre, pero en este caso acudir a la negociación, a la mediación, a la conciliación... parece fuera de contexto (176).

En el segundo caso, las controversias, por el contrario, se plantearían con

estos términos: ¿ha incumplido el Estado C su obligación de no prestar ayuda y asistencia al Estado A, autor del crimen, en orden a no mantener la situación originada por éste hecho?; ¿es lícita la medida adoptada por el Estado D contra el Estado A, autor de un crimen que ha dañado directa y especialmente al Estado B?... En estos casos, cualquiera de los medios o procedimientos previstos por el Derecho internacional para la solución de diferencias puede ser válido. Ahora bien, de entre éstos, en mi opinión, el más idóneo es el arreglo judicial, en especial, por la Corte Internacional de Justicia, sin perjuicio de la competencia de otros órganos de Naciones Unidas y, en particular, del Consejo de Seguridad (177).

En esta línea, la tercera parte del proyecto presentado por Willen RIPHAGEN, que sigue el modelo de los artículos 65 y ss. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados (aunque en su conjunto necesita de una profunda revisión tanto respecto de la forma como del contenido), prevé -interpretándose correctamente- que cumplidos ciertos trámites y no resolviéndose la controversia en un tiempo determinado por cualquiera de los medios indicados en el artículo 33 de la Carta, "cualquiera de las partes en una controversia relativa a los demás derechos y obligaciones a que se hace referencia en el artículo 14 de la segunda parte de los presentes artículos podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia" (proyecto de art. 4.b) (178).

Sin embargo, además de aquellas controversias existen otras que podrían plantearse, más específicamente, de la siguiente forma: ¿es lícita la medida adoptada por el Estado F, por vía de represalia, en virtud de la cual se procede a suspender el cumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto del Estado A, autor de un crimen internacional? En este caso, la controversia trataría sobre la interpretación o la aplicación de los artículos 9 y siguientes de la segunda parte del pro-

(174) "Contramedidas respecto a un hecho internacionalmente ilícito". El anteproyecto del art. 30 presentado por AGO llevaba por título "Ejercicio legítimo de una sanción" (A.C.D.I. 1979, vol. II, 1ª parte, p. 46).

(175) A.C.D.I. 1979, vol. II, 2ª parte, p. 145, par. 21.

(176) A.C.D.I. 1973, vol. II, p. 178.

(177) "Chronique des faits..." cit., R.G.D.I.P., tomo 84/1980/3, p. 884.

(178) Por ejemplo, en la resolución 36/27 de la A.G. citada supra puede leerse lo siguiente: "Pide de nuevo al Consejo de Seguridad que instituya medidas coercitivas eficaces para impedir que Israel siga poniendo en peligro la paz y..." (el subrayado es mío). Un comentario más general a este respecto puede verse en CARDONA LLORENS, J., op. cit., pp. 322 ss.

(179) ARANGIO RUIZ, G., Informe preliminar... cit., p. 27.

(175) Véase, por ejemplo, Sexto informe... cit., p. 19, par. 32.

(176) Para RIPHAGEN, "es claro que, además de las cuestiones 'normales' relacionadas con los hechos del caso, se puede plantear una controversia relativa a la calificación de esos hechos... claro es que esa calificación no puede quedar al arbitrio de cada Estado" (Sexto informe... cit., p. 19, par. 31; el subrayado es mío).

(177) En la tercera parte del proyecto presentado por RIPHAGEN no se hace referencia al artículo 15 de la segunda parte (consecuencias jurídicas adicionales de la agresión) "por la razón -según explicó el Relator especial- de que la (pregunta) agresión y la pretensión conexa de legítima defensa deben examinarse en primer lugar de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. El hecho de que corresponda a la C.I.J. una función en ese proceso, el ámbito de esa función y la forma en que la ha de desempeñar son cuestiones de interpretación y aplicación de la propia Carta" (Séptimo informe... cit., p. 5).

(179) Obviamente, no todos los miembros de la C.D.I. estuvieron de acuerdo con la jurisdicción de la C.I.J. En general, véase A.C.D.I. 1986, vol. II, 2ª parte, p. 39, par. 48. Igualmente, SPINEDI, M., op. cit., pp. 71 y 97 ss.

(179) Como reconocieron algunos miembros de la C.D.I., la tercera parte del proyecto tenía un alcance limitado (A.C.D.I. 1986, vol. II, 2ª parte, p. 39, par. 49). Es evidente, por otra parte, que los Estados siempre pueden acudir a la Corte por una vía de jurisdicción distinta.

(180) Tercer informe... cit., p. 52, par. 130.

(181) Véase el artículo 5, apartado d), de la segunda parte del proyecto presentado por W. RIPHAGEN.

(182) Informe preliminar... cit., p. 127, par. 66. Igual reconocimiento hay que deducir de AGO (véase *supra*, nota 10).

(183) Véanse los artículos 18-2º, 29-2º y 33-2ºa, de la primera parte del proyecto y el 12 de la segunda.⁵⁹

yecto. Pues bien, según el proyecto de RIPHAGEN, este supuesto, extrañamente, cae fuera de la jurisdicción de la Corte, previéndose, por el contrario, un procedimiento de conciliación⁽¹⁷⁹⁾.

IV. CONCLUSIÓN

La nueva (o relativamente nueva) figura del crimen internacional, en efecto ha roto el clásico esquema de la relación jurídica de responsabilidad internacional; en palabras de Willen RIPHAGEN, el concepto mismo de "crimen" supone "una desviación... del planteamiento tradicional de bilateralismo y la reparación en los asuntos internacionales"⁽¹⁸⁰⁾.

Cierto es que el bilateralismo no sólo se supera con la introducción de ese tipo delictivo: piénsese en la simple violación de una norma de *ius cogens* o también en la violación de obligaciones impuestas por un tratado multilateral⁽¹⁸¹⁾. Incluso debe afirmarse, especialmente respecto del primer caso, que algunos de los puntos del régimen de responsabilidad abordado no son privativos de los crímenes internacionales. En este sentido, el anterior Relator especial, Willen RIPHAGEN, reconoció que la posición no neutral de cada tercer Estado "es una consecuencia jurídica de un hecho ilícito que no está reservado necesariamente a hechos ilícitos como los que constituyen crímenes internacionales"⁽¹⁸²⁾.

Sin embargo, nada parecido se recoge expresamente en las diversas partes del proyecto presentadas hasta el momento; por el contrario, y con buen criterio, sí se ocupan del *ius cogens* como elemento corrector, como factor canalizador, como techo que debe observarse tanto en la constitución como en el contenido de toda relación jurídica

ca de responsabilidad internacional⁽¹⁸³⁾.

En cualquier caso, las respuestas al crimen internacional son más o mayores, o diferentes si se quiere: normalmente, el apartado de Naciones Unidas no se pondrá en marcha ante una simple violación de una norma "imperativa" y las medidas de represalia adoptadas por "terceros Estados" respecto de esta previa violación no serán lícitas.

A la vez, esas respuestas, si mayores o diferentes, son las previstas por el Derecho internacional contemporáneo, y es Derecho internacional que el Consejo de Seguridad de N.U., aún en el caso de crímenes evidentes, considere conveniente no imponer sanciones (o que adquiriera en el futuro una práctica distinta) y también lo es, en mi opinión, que los Estados, con ciertos límites, puedan decidir medidas coercitivas contra el autor del crimen. Pero lo que no es Derecho internacional contemporáneo es el que ojalá fuese o el Derecho de las sociedades estatales.

De ello creo que ha tomado buena nota Willen RIPHAGEN, cuyo trabajo, en general, debe ser valorado positivamente, y más si se tiene en cuenta lo difícil y delicado de la segunda parte del proyecto. Ahora bien, aunque haya tenido en cuenta esa realidad, pensando o no en la respuesta de los Estados, el resultado da a menudo la impresión de ambigüedad, lo que no parece una vía aceptable, al menos para el proyecto que debe presentar un órgano como la C.D.I. El resultado final dependerá de una futura "conferencia de plenipotenciarios", donde claramente se expondrán las posiciones estatales, pero antes hay que allanar el terreno, y el jurista debe hacerlo con la claridad, la técnica (y también con el realismo) que le han de caracterizar.